

# 114一試詳解-行政法

## Q01 | 行政法源大檢閱：自治法規、國家緊急權、司法變革與不成文法源之交錯網

關於行政法之法源，下列敘述何者正確？

- (A)自治條例雖無須特定法律之授權，仍可限制人民權利
- (B)總統發布之緊急命令，乃是位階等同於法規命令之成文法源
- (C)大法庭制度施行後，法官審判時即不得再參考判例及決議
- (D)行政程序法施行後，基於依法行政原則，習慣法已失其法源地位

### Analysis | 破題思路

(A)

釋字第738號，就其自治事項或依法律及上級法規之授權，以自治條例規範居民之權利義務，故「雖無須特定法律之授權，仍可限制人民權利」為正確之敘述。

(B)

釋字第543號，緊急命令具有「暫時替代或變更法律效力」之命令，故「位階等同於法規命令之成文法源」為錯誤之敘述。

(C)

大法庭新制施行後，判例與決議之效力均已大幅調整，就判例而言，僅有要旨而無全文者將停用，其餘未停用之判例亦不再具有通案拘束力；就決議而言，不再以決議制度統一法律見解，現有決議內容供法官參考。

「法官審判時即不得再參考判例及決議」為錯誤之敘述。

還願專用。嚴禁營利轉售

(D)

108年度簡字第160號判決，行政法裡，法源既包括成文法，也包括不成文法源，後者尚包括法律原則，習慣法。

「習慣法已失其法源地位」為錯誤之敘述。

### Court View | 法院目前怎麼看？

#### 釋字第738號

人民營業之自由為憲法第十五條工作權及財產權所保障之內涵。人民如以從事一定之營業為其職業，關於營業場所之選定亦受營業自由保障，僅得以法律或法律明確授權之命令，為必要之限制，惟若僅屬執行法律之細節性、技術性次要事項，得由主管機關發布命令為必要之規範，而無違於憲法第二十三條法律保留原則之要求，迭經本院解釋在案（本院釋字第四四三號、第七一六號及第七一九號解釋參照）。又憲法規定我國實施地方自治。依憲法第一百十八條及憲法增修條文第九條第一項規定制定公布之地方制度法，為實施地方自治之依據。依地方制度法第二十五條及第二十八條第二款規定，地方自治團體得就其自治事項或依法律及上級法規之授權，以自治條例規範居民之權利義務，惟其內容仍不得抵觸憲法有關中央與地方權限劃分之規定、法律保留原則及比例原則。

#### 釋字第543號

憲法增修條文第二條第三項規定：「總統為避免國家或人民遭遇緊急危難或應付財政經濟上重大變故，得經行政院會議之決議發布緊急命令，為必要之處置，不受憲法第四十三條之限制。但須於發布命令後十日內提交立法院追認，如立法院不同意時，該緊急命令立即失效。」由此可知，緊急命令係總統為應付緊急危難或重大變故，直接依憲法授權所發布，具有暫時替代或變更法律效力之命令，其內容應力求周延，以不得再授權為補充規定即可逕予執行為原則。若因事起倉促，一時之間不能就相關細節性、技術性事項鉅細靡遺悉加規範，而有待執行機關以命令補充，方

還願專用。嚴禁營利轉售

能有效達成緊急命令之目的者，則應於緊急命令中明文規定其意旨，於立法院完成追認程序後，再行發布。此種補充規定應依行政命令之審查程序送交立法院審查，以符憲政秩序。又補充規定應隨緊急命令有效期限屆滿而失其效力，乃屬當然。

#### 臺灣新北地方法院108年度簡字第160號判決

所謂依法行政原則（law-based administration）乃支配法治國行政權與立法權之首要原則，亦即一切行政行為應遵守之必要原則。簡而言之，乃指行政權力之行使必須依據法律之規範為之。在積極的面向上，要求行政行為須有法律之依據；在消極的面向上，則要求行政行為不得牴觸法律。所以依法行政原則在積極的面向上體現為法律優越或法律優位，它不僅要求行政處分需有法律的授權，更主要包括行政機關的處分必須受法律的限制。而此處的法律並非僅只是實定法，而是與行政法法源同義的廣義概念。在行政法裡，法源既包括成文法，也包括不成文法源。後者尚包括法律原則，習慣法等。作為大陸法系行政法體系的綱領性原則，法律優越之意義不僅僅只是要求行政機關的行為必須具有合法性，同時是引出對經由立法機關授權的行政立法和行政自由裁量權的限制，一方面，公民得以依此原則進行訴願和訴訟的權利得以確立，同時法院對委任立法和自由裁量進行審查的權利得到確認和保障。

## Q02 | 時間權限的「信賴突襲」：解析限期改善處分之實質拘束力與公信力

環保機關查獲地下油槽滲漏污染地下水，通知負責人限期改善，否則依法處罰，惟在限期改善期限屆至前，即對油槽之負責人裁處罰鍰。關於環保機關之裁罰行為，下列敘述何者正確？

- (A)違反比例原則
- (B)裁罰處分無效
- (C)基於維護公益並未違法
- (D)違反誠實信用原則

### Legal Basis | 法條依據

✦ 行政程序法8條：「行政行為，應以誠實信用之方法為之，並應保護人民正當合理之信賴。」

### Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

104年度簡字第146號判決，限期改善期限屆至前，即對油槽之負責人裁處罰鍰，乃違反誠實信用原則。

### 🏛️ Court View | 法院目前怎麼看？

#### 臺灣桃園地方法院104年度簡字第146號判決

,,函釋：「主旨：事業因不符放流水標準，違反水污染防治法第7條並依第40條限期改善，環保機關開立限期改善公文送達前，再次違反水污染防治法第7條時，其執行方式詳如說明。說明：二環保機關開立限期改善公文送達前，事業再受環保機關

第2次查驗水質未符標準，考量行政行為以最少侵害性與合目的性為原則，如第2次之稽查結果較第1次之稽查結果違犯情節相等或較輕微，則顯示第1次行政處分即可達成行政目的，第2次採樣結果應不予處分或所為之處分應予撤銷。倘非屬上開情形，行政處分尚未送達前之第2次違規行為仍應以違反水污染防治法第7條規定予以處分，並限期改善，惟其改善期限仍應以第1次裁定之期限為期限。」乃係依據限期改善之立法意旨，並基於行政行為最少侵害性與合目的性之原則，就限期改善期間內應如何稽查裁處所為之解釋，以供下級機關作為執行之依據，並未逾越水污染防治法相關規定，亦無原告所指違反比例原則及法律保留原則之情事，自可適用。準此，事業於環保機關開立之限期改善公文送達前，經稽查檢驗結果再次違反水污染防治法第7條規定，惟如其排放廢水水質並無惡化情事，亦即未超過前次限期改善之水質檢驗值，即不應再予處分（亦參北高行97年度訴字第2547號判決）。…。(3)則就本件違規而言，被告進行稽查、採樣及檢測之時間為103年11月26日，乃是被告前揭103年8月22日准予備查函文並同意之一年改善期內，雖然此次之檢測結果未符標準，然參照前述原告之多次檢測結果，可知此次之化學需氧量116mg/L（放流水標準為100mg/L），係歷來最接近標準值之紀錄，是應可認定原告之前揭「擴（整）建與功能提升工程」、「改善工程計畫」雖均因故尚未完工，然原告確有盡力於改善其水質之處理，且以此次之檢測結果（116mg/L）與標準值相去不遠以觀，亦足認應符合被告前述103年8月22日函文所指之「短期改善工程」、甚至是「中期改善工程」。是以，考量本件之採樣時間為103年11月26日，尚屬被告所通知原告污水處理廠之中期改善工程期間，並綜合審酌水污染防治法之立法目的、法規之合目的性、環保署前揭函釋之意旨，及比例原則、誠信原則等，本院認為原告此次103年11月26日之違規情形，應不予處罰。

## Q03 | 司法審查的「神聖停火區」：不確定法律概念下「判斷餘地」之承認與審查密度變奏

依據學說與司法實務見解，對於不確定法律概念是否具有判斷餘地，下列敘述何者錯誤？

- (A)考試成績之評定，閱卷委員應有判斷餘地，但若試題屬簡答題且評分標準已客觀明確，即無判斷餘地
- (B)學校依據性別平等教育法就校園性別事件組成之調查小組，其調查報告對於性騷擾之事實認定屬於判斷餘地，法院應受拘束
- (C)行政機關就其事項雖具有判斷餘地，但若有出於與事物無關之考量之情事，法院仍得介入審查
- (D)獨立委員會所作成的評價決定具有判斷餘地，行政法院之審查應受到限制，但涉及人民基本權利屬性的判斷，仍應提高審查密度

### Analysis | 破題思路

(A)

105年訴字第 405 號，一般申論題，法院固應尊重閱卷委員學術專業上之判斷餘地；簡答題，法院即得審查閱卷委員之評分是否符合標準答案及一致性之評分標準，故於此範圍內，難認閱卷委員有何判斷餘地之可言。

「若試題屬簡答題且評分標準已客觀明確，即無判斷餘地」為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故A不選。

(B)

高等行政法院110年度訴字第538號判決，法院對於相關事實之認定，只是「應審酌」各級性平會之調查報告，而不是受其拘束，被告辯稱：系爭調查報告享有判斷餘地云云，尚不足採。

還願專用。嚴禁營利轉售

還願專用。嚴禁營利轉售

「查報告對於性騷擾之事實認定屬於判斷餘地，法院應受拘束」，為錯誤之敘述，而本題要選錯誤的，故選B。

(C)

114年度上字第203號判決，只在判斷有恣意濫用及其他違法情事，是否出於錯誤之事實認定或不完全之資訊等例外情形時，才予以撤銷或變更。

「若有出於與事物無關之考量之情事，法院仍得介入審查」為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故C不選。

(D)

109年度上字第838號判決，又其判斷若涉及人民基本權之限制，自應採較高之審查密度。

「涉及人民基本權利屬性的判斷，仍應提高審查密度」為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故D不選。

## Court View | 法院目前怎麼看？

### 裁判字號：105年訴字第 405 號

次按閱卷委員針對申論題所為之評分，係根據其個人學識經驗所為專門學術上獨立公正之智識判斷，因具有高度之專業性及屬人性，故為維護考試之客觀與公平及閱卷委員所為之學術評價，此項評分之法律性質，固應屬於閱卷委員之判斷餘地，亦即閱卷委員就申論題所為之評分原則上應受尊重，其他機關甚至法院亦不得以其自己之判斷，代替閱卷委員之判斷。惟除性質上特殊之計算題及繪圖題外，形式上屬於由應考人以文字敘述之申論式題型，至少應區分有待應考人進一步依題旨申論己意且無標準答案之一般申論題，以及無待申論且有標準答案之簡答題等二大類，而分別其評分方式：針對無標準答案之一般申論題，閱卷委員固得本諸其學術專業及

一致性之評分標準，就應考人之申論內容予以評分；惟如係有標準答案之簡答題，閱卷委員則應依照標準答案及一致性之評分標準，就應考人之作答內容是否符合標準答案予以評分。而行政法院就閱卷委員針對申論式題型所為評分之審查密度，亦應區分一般申論題或簡答題而有異：針對前者，法院因應尊重閱卷委員學術專業上之判斷餘地；惟如係針對後者，法院即得審查閱卷委員之評分是否符合標準答案及一致性之評分標準，故於此範圍內，難認閱卷委員有何判斷餘地之可言。

### 臺北高等行政法院110年度訴字第538號判決

然法院基於行政訴訟之職權就事實之認定調查原則，必須充分調查為裁判基礎之事實以形成心證，依性平法第35條第2項規定，法院對於相關事實之認定，只是「應審酌」各級性平會之調查報告，而不是受其拘束，法院就該調查報告之審酌，仍應踐行證據之調查及全辯論意旨以形成心證，並於判決理由中，就事實認定之結果，敘明得心證之理由。是有關性平會之調查報告相關事實認定部分，與不確定法律概念之解釋與涵攝無涉，應由法院依職權調查證據後予以判斷，並無尊重行政機關判斷餘地問題（最高行政法院107年度判字第615號判決參照）。依上說明，可悉性平法第2條第4款第1目之性騷擾行為，法律規定要件明確，關於個案事實之認定，法院固應審酌性平會之調查報告，至「性騷擾」則屬評價性之不確定法律概念，而得由行政法院為全面審查，是否構成「性騷擾」，係以「合理被害人」（因隨個人的性別差異、性向傾向差異、成長背景、思想觀念、人際互動模式、當下情境等條件等，而可能發生迥異的看法及感受），即受害人主觀感受作為衡酌基準，至於加害行為人之「意圖」尚非構成「性騷擾」之必備構成要件。則被告辯稱：系爭調查報告享有判斷餘地云云，尚不足採，首先說明。

### 最高行政法院114年度上字第203號判決

前揭服役條例、考評具體作法規定所稱之「不適服現役」，屬於不確定法律概念，人評會（含再審議人評會）針對被上訴人是否「適服現役」之考評判斷，具有高度屬人性，系爭個案是否該當於「不適服現役」，行政法院承認行政機關就此等事項之決定有判斷餘地，而對其判斷採取較低密度之審查，原則上法院不可以自己之判

斷，代替人評會之判斷，只在判斷有恣意濫用及其他違法情事，包括：1. 行政機關之判斷，是否出於錯誤之事實認定或不完全之資訊。2. 法律概念涉及事實關係時，其涵攝有無明顯錯誤。3. 對法律概念之解釋有無明顯違背解釋法則或抵觸既存之上位規範。4. 行政機關之判斷，是否有違一般公認之價值判斷標準。5. 行政機關之判斷，是否出於與事物無關之考量，亦即違反不當聯結之禁止。6. 行政機關之判斷，是否違反法定之正當程序。7. 作成判斷之行政機關，其組織是否合法且有判斷之權限。8. 行政機關之判斷，是否違反相關法治國家應遵守之原理原則，如平等原則、公益原則等例外情形時，才予以撤銷或變更。因此，關於不服現役之判斷，若有前揭事由，行政法院始得認原處分違法而予撤銷。

#### 最高行政法院109年度上字第838號判決

再查，醫藥事故涉及高度專業，主張受害之一方面對專業領域之深奧複雜，可謂為知識上之弱勢者，故特別仰賴專家之專業、公正判斷。本件涉及人民之生命、健康等基本權，專家享有高度之權威，對於專業認知不足且無能為力之受害人，應盡力釋疑，以昭公信。司法審判上，對此涉及人民基本權之專家判斷，應提高審查密度，調查專業論證上之說明，有無判斷錯誤，有無重要事項漏未斟酌等等。司法院釋字第553號解釋理由書亦一併指明「事件之性質影響審查之密度，單純不確定法律概念之解釋與同時涉及科技、環保、醫藥、能力或學識測驗者，對原判斷之尊重即有差異。又其判斷若涉及人民基本權之限制，自應採較高之審查密度。」、「是否尚有其他重要事項漏未斟酌」。

## Q04 | 裁量基準與行政自我拘束：通案效力、裁量怠惰、個案正義與處分適法性

行政機關依職權訂定裁量基準，其所屬機關在處理具體個案時認為個案情形特殊，未依此裁量基準作成個案裁量決定，有關此個案裁量決定，下列敘述何者正確？

- (A)即使具體個案情況特殊，所屬機關仍須遵守裁量基準
- (B)裁量基準為行政指導準則，對所屬機關具事實拘束力
- (C)裁量本屬個案決定，故具通案性質之裁量基準係供下屬參考用
- (D)為達成具體個案之公平正義，此裁量可依個案特殊情形而定

### Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

110年度上字第439號判決，行政機關訂定之裁量基準，該具體個案如有特殊狀況，與裁量基準所定之典型案例情節有所不同時，自應本於法律授權目的為裁量，作成不同於裁量基準之決定，俾符個案之實質正義，否則即構成裁量怠惰之違法。

「為達成具體個案之公平正義，此裁量可依個案特殊情形而定」為正確之敘述。

### 🏛️ Court View | 法院目前怎麼看？

#### 最高行政法院110年度上字第439號判決

行政罰法第18條第1項規定：「裁處罰鍰，應審酌違反行政法上義務行為應受責難程度、所生影響及因違反行政法上義務所得之利益，並得考量受處罰者之資力。」是以，對人民違反行政法上義務之行為處以罰鍰，其違規情節有區分輕重程度之可能與必要者，應依具體個案情節，根據違反義務情節之輕重程度為適當考量及裁量，使責罰相當，以符合法律授權裁量之意旨，及法治國所應遵循之比例原則及平等原則（司法院釋字第641號解釋理由書參照）。另行政機關為協助所屬人員或下級機關

還願專用。嚴禁營利轉售

還願專用。嚴禁營利轉售

行使裁量權，並維持法律適用之一致性及符合平等原則，固得訂頒裁量基準，供作所屬人員或下級機關於個案行使裁量權之準據（行政程序法第159條第2項第2款參照）。惟行政機關訂定之裁量基準，應遵循法律授權之目的及範圍，且其裁量時所取決者，僅就典型之案例為規定，而非具體之個案。故行政機關於個案行使裁量權時，原則上應受裁量基準之拘束（行政程序法第161條參照），但該具體個案如有特殊狀況或考慮行政罰法第18條第1項之審酌因素後，與裁量基準所定之典型案例情節有所不同時，自應本於法律授權目的為裁量，作成不同於裁量基準之決定，俾符個案之實質正義，否則即構成裁量怠惰之違法。

## Q05 | 脫下官服的行政機關：國庫行政、雙階理論與公私法法律關係之劃界

下列何者不發生行政法之法律關係？

- (A) 人民因亂丟垃圾而受主管機關裁處罰鍰
- (B) 行政機關與人民締結契約，授予人民行使公權力之權限
- (C) 政府採購案之得標廠商與採購機關所訂定之採購契約
- (D) 地方政府之垃圾車於執行職務時撞傷人民

### Analysis | 破題思路

(A)

94年度判字第21號判決，裁處罰鍰，行政處分之內容，無論其為下命、形成或確認，均會產生一種「行政法之法律關係」。

「因亂丟垃圾而受主管機關裁處罰鍰，不發生行政法之法律關係」為錯誤之敘述。

(B)

臺灣桃園地方法院102年度簡字第116號判決，行政機關，顯非居於單純財產權之主體地位，而欲與被告締結系爭契約均得出其等屬「公法」性質法規之一致結論，而無任一標準可以得出其屬私法法規之性質。

「行政機關與人民締結契約，授予人民行使公權力之權限，不發生行政法之法律關係」為錯誤之敘述。



(C)

102年度判字第151號判決，採購契約履約問題而不予發還押標金所生之爭議，屬私權爭執，非公法上爭議。

「得標廠商與採購機關所訂定之採購契約，不發生行政法之法律關係」為正確之敘述。

(D)

105年度上易字第28號民事判決，駕駛垃圾車至各家收集垃圾，係屬國家福利行政（給付行政）範圍，為行使公權力之行為。於執行公務時因過失撞傷○○○，○○○依國家賠償法第二條第二項規定請求馬公市公所賠償損害，自屬有據，此項公法行為固可廣及於提供給付、服務、救濟、照顧等方法以達成國家任務之行為。

「垃圾車於執行職務時撞傷人民，不發生行政法之法律關係」為錯誤之敘述。

## Court View | 法院目前怎麼看？

### 最高行政法院94年度判字第21號判決

本院查：按行政處分之內容，無論其為下命、形成或確認，均會產生一種行政法之法律關係，其所確認或據以成立之事實關係，與其他行政處分之事項有牽連時，應視為該行政處分之構成要件事實。行政機關應予以承認及接受。又課稅處分之基礎事實為終局判決所確定，行政法院亦應受其拘束（改制前本院29年判字第13號判例參照）。查上訴人依法為應使用統一發票之商戶，於86年間銷售溶劑油，銷售額43,378,300元，營業稅額2,168,915元，未依規定開立統一發票，亦未於規定期限內向被上訴人申報銷售額繳納營業稅，致生逃漏稅額2,168,915元，業經臺南市稅捐稽徵處補徵該上訴人營業稅及裁處罰鍰，上訴人不服，循序提起行政訴訟，亦經本院以90年度判字第1808號判決駁回確定在案，為原審所認定之事實，該營業稅課稅處

分即為本件營利事業所得稅課稅處分之構成要件事實，依首揭說明及判例意旨，上訴人自不得於本件訴訟，再為與該確定判決意旨相反之主張。

### 臺灣桃園地方法院102年度簡字第116號判決

查原告屬行政機關，業如前述，其所以與被告發生本件法律關係進而訴訟，係為踐行其代表國家致力促進勞工就業之給付行政行為，此等行為亦僅有原告始得辦理，原告於此顯非居於單純財產權之主體地位，而欲與被告締結系爭契約，毋寧係「以國家權力主體的資格」而適用就業服務法（第二十四條）及上述相關辦法、要點，且除原告及其所屬二級機關外，依法尚無其他人可以為此部分促進勞工就業保障者。換言之，此給付發給係原告為遂行其給付行政任務之「職務法」，其屬公法之特別法，殆無疑義。3綜上所述，不論依前述何項學說檢驗就業服務法、就業安定基金收支保管及運用辦法、關廠歇業失業勞工促進就業貸款實施要點。均得出其等屬「公法」性質法規之一致結論，而無任一標準可以得出其屬私法法規之性質。是其等屬公法法規性質，當無疑義。

### 最高行政法院102年度判字第151號判決

(一)按「政府採購法第74條規定：『廠商與機關間關於招標、審標、決標之爭議，得依本章規定提出異議及申訴。』採購申訴審議委員會對申訴所作之審議判斷，依同法第83條規定，視同訴願決定。準此，立法者已就政府採購法中廠商與機關間關於招標、審標、決標之爭議，規定屬於公法上爭議，其訴訟事件自應由行政法院審判。……至本院93年2月份庭長法官聯席會議決議之法律問題，係關於採購契約履約問題而不予發還押標金所生之爭議，屬私權爭執，非公法上爭議，行政法院自無審判權，與本件係廠商與機關間關於決標之爭議，屬公法上爭議有間，附此敘明。」經本院97年5月份第1次庭長法官聯席會議決議在案。本件係被上訴人依政府採購法第31條第2項第8款規定，於系爭採購案之工程採購投標須知第13點第1項第8款為「投標廠商有『其他經主管機關認定有影響採購公正之違反法令行為』之情形者，其所繳納之押標金，不予發還，其已發還者，並予追繳。」之規定，並以上訴人參與系爭採購案之投標時有圍標情事，有影響採購公正之違反法令行為而追繳已發還

之押標金，核屬於決標前上訴人有無「其他經主管機關認定有影響採購公正之違反法令行為」之情形暨被上訴人得否「追繳前已發還之押標金」等招標之爭議，而非兩造訂約後之履約爭議問題，揆諸政府採購法第74條、第83條規定及本院上開庭長法官聯席會議決議意旨，屬於公法上爭議，行政法院自有審判權。上訴人原僅主張被上訴人所為之追繳處分係屬裁罰性質、其請求權已罹於時效而消滅等情，循行政爭訟之程序而訴請撤銷原處分，上訴意旨逕以其就系爭採購案已訂約並履行完畢，本件應屬私權糾紛，應循私權爭議途徑解決，自非有據，且前後主張顯互相矛盾。

之行為，但國家機關如僅立於私法主體之地位，從事一般行政之補助行為者，即與行使公權力有間，不生國家賠償法適用之問題。

#### **臺灣高等法院花蓮分院105年度上易字第28號民事判決**

須為執行職務行使公權力之行為之要件部分：(1)實務見解一致認為國家賠償法第2條第2項所謂行使公權力係指公務員居於國家機關之地位，行使統治權作用之行為而言，並包括運用命令及強制等手段干預人民自由及權利之行為，以及提供給付、服務、救濟、照顧等方法，增進公共及社會成員之利益，以達成國家任務之行為。垃圾車司機定時駕駛垃圾車至各指定地點收集垃圾，而民眾亦須依規定於定時定點放置垃圾，不得任意棄置，此為國家福利行政（給付行政）範圍，為公務員行使公權力之行為（最高法院94年度臺上字第1115號、93年度臺上字第255號、92年度臺上字第740號、88年度臺上字第2214號判決意旨參照）。「本件肇事垃圾車之司機莊丁榜為馬公市公所清潔隊員，駕駛垃圾車至各家收集垃圾，係屬國家福利行政（給付行政）範圍，為行使公權力之行為。於執行公務時因過失撞傷○○○，○○○依國家賠償法第二條第二項規定請求馬公市公所賠償損害，自屬有據。」（最高法院88年度臺上字第2214號判決意旨參照）。「原審既認定被上訴人趙○○係被上訴人台南市政府環保局之司機，駕駛該局之垃圾車收集垃圾而執行職務，發生本件車禍，則上訴人依民法第一百八十八條規定，請求被上訴人台南市政府負連帶賠償責任，原審本此見解為上訴人敗訴之判決，經核並無違背法令情形。」（最高法院94年度臺上字第1115號判決意旨參照）。並進一步認為「國家賠償法第二條第二項所稱之『行使公權力』，係指公務員居於國家機關之地位，行使統治權作用之公法行為而言。此項公法行為因可廣及於提供給付、服務、救濟、照顧等方法以達成國家任務



## Q06 | 行政院의 「院外特區」：行政組織法下「獨立機關」之法定要件與功能定性

下列行政機關之委員，何者不受依法獨立行使職權之保障？

- (A) 中央選舉委員會
- (B) 公務人員保障暨培訓委員會
- (C) 金融監督管理委員會
- (D) 國家運輸安全調查委員會

### Legal Basis | 法條依據

✦ 中央行政機關組織基準法3條2款：「二、獨立機關：指依據法律獨立行使職權，自主運作，除法律另有規定外，不受其他機關指揮監督之合議制機關。」

✦ 行政院組織法9條：「行政院設下列相當中央二級獨立機關：

- 一、中央選舉委員會。
- 二、公平交易委員會。
- 三、國家通訊傳播委員會。」

✦ 中央選舉委員會組織法5條2項：「本會委員應超出黨派以外，依法獨立行使職權，於任職期間不得參加政黨活動。」

✦ 公務人員保障暨培訓委員會組織法6條3項：「本會委員於審議、決定有關公務人員保障事件時，應超出黨派，依據法律獨立行使職權。」

✦ 行政院組織法4條：「行政院設下列各委員會：

- 一、國家發展委員會。
- 二、國家科學及技術委員會。

還願專用。嚴禁營利轉售

三、大陸委員會。

四、金融監督管理委員會。

五、海洋委員會。

六、僑務委員會。

七、國軍退役官兵輔導委員會。

八、原住民族委員會。

九、客家委員會。」

✦ 國家運輸安全調查委員會組織法1條：「行政院為獨立公正調查航空、鐵道、水路及公路之重大運輸事故，特設國家運輸安全調查委員會（以下簡稱本會），為相當中央三級獨立機關。」

✦ 國家運輸安全調查委員會組織法3條1項：「本會依法獨立行使職權。」

### Analysis | 破題思路

(A)

行政院組織法9條、中央選舉委員會組織法5條2項，中央選舉委員會，為相當中央二級獨立機關，依法獨立行使職權，故「中央選舉委員會，不受依法獨立行使職權之保障」為錯誤之敘述。

(B)

公務人員保障暨培訓委員會組織法6條3項，公務人員保障暨培訓委員會，依據法律獨立行使職權，故「公務人員保障暨培訓委員會，不受依法獨立行使職權之保障」為錯誤之敘述。

(C)

行政院組織法4條4款，行政院設金融監督管理委員會，故「金融監督管理委員會，不受依法獨立行使職權之保障」為正確之敘述。

還願專用。嚴禁營利轉售

(D)

國家運輸安全調查委員會組織法1條、3條1項，國家運輸安全調查委員會，為相當中央三級獨立機關，依法獨立行使職權，故「國家運輸安全調查委員會，不受依法獨立行使職權之保障」為錯誤之敘述。

## Q07 | 機關搬家的「交接條款」：組織改造下管轄權變更公告之程式與未結舊案之流向

組織法規修正後，甲機關之某項職掌移由乙機關管轄時，下列敘述何者錯誤？

(A)若相關行政法規仍規定甲機關為管轄機關，且甲機關仍存續時，甲機關與乙機關得聯名公告變更管轄之事項

(B)若甲機關被裁撤，其中部分職掌由乙機關承受，但相關行政法規仍載明甲機關為管轄機關，得由乙機關單獨公告變更管轄之事項

(C)關於機關管轄變更之公告，原則上自公告之日起算至第3日起發生移轉管轄權之效力

(D)若甲機關尚有1件已受理之申請案，甲機關雖然存續但已不再具有本案管轄權，則甲機關原則上仍得繼續處理本案

### Legal Basis | 法條依據

✦ 行政程序法11條2項：「行政機關之組織法規變更管轄權之規定，而相關行政法規所定管轄機關尚未一併修正時，原管轄機關得會同組織法規變更後之管轄機關公告或逕由其共同上級機關公告變更管轄之事項。」

✦ 行政程序法11條3項：「行政機關經裁併者，前項公告得僅由組織法規變更後之管轄機關為之。」

✦ 行政程序法11條4項：「前二項公告事項，自公告之日起算至第三日起發生移轉管轄權之效力。但公告特定有生效日期者，依其規定。」

✦ 行政程序法18條：「行政機關因法規或事實之變更而喪失管轄權時，應將案件移送有管轄權之機關，並通知當事人。但經當事人及有管轄權機關之同意，亦得由原管轄機關繼續處理該案件。」

### Analysis | 破題思路

(A)

行政程序法11條2項，原管轄機關得會同組織法規變更後之管轄機關公告，故「甲機關與乙機關得聯名公告變更管轄之事項」，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故A不選。

(B)

行政程序法11條3項，公告得僅由組織法規變更後之管轄機關為之，故「得由乙機關單獨公告變更管轄之事項」，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故B不選。

(C)

行政程序法11條4項，原則上自公告之日起算至第三日起發生移轉管轄權之效力，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故C不選。

(D)

行政程序法18條，行政機關喪失管轄權，應將案件移送有管轄權之機關，故「甲機關原則上仍得繼續處理本案」，為錯誤之敘述，而本題要選錯誤的，故選D。

## Q08 | 地方立法權的四重奏：自治條例、自治規

### 則、委辦規則與自律規則之劃界

建築法規定，非縣政府所在地之鄉、鎮，適用本法之地區，非供公眾使用之建築物或雜項工作物，得委由鄉、鎮公所依規定核發執照。若鄉、鎮公所欲就核發此執照之事項形成相關規定，應以下列何種規範為之？

- (A) 自治規則
- ☒ (B) 委辦規則
- (C) 委託規則
- (D) 自律規則

### Legal Basis | 法條依據

✦ 地方制度法2條3款：「三、委辦事項：指地方自治團體依法律、上級法規或規章規定，在上級政府指揮監督下，執行上級政府交付辦理之非屬該團體事務，而負其行政執行責任之事項。」

✦ 地方制度法29條1項：「直轄市政府、縣（市）政府、鄉（鎮、市）公所為辦理上級機關委辦事項，得依其法定職權或基於法律、中央法規之授權，訂定委辦規則。」

### Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

地方制度法2條3款、29條1項，地方自治團體鄉、鎮公所依建築法規定，負其行政執行責任之事項依規定核發執照，應以「委辦規則」規範為之。

## 🏛️ Court View | 法院目前怎麼看？

### 臺中高等行政法院101年度訴字第491號裁定

四、惟按地方制度法第2條第3款規定：「本法用詞之定義如下：．．．三、委辦事項：指地方自治團體依法律、上級法規或規章規定，在上級政府指揮監督下，執行上級政府交付辦理之非屬該團體事務，而負其行政執行責任之事項。」第19條第1項第6款第2目規定：「下列各款為縣（市）自治事項；六、關於都市計畫及營建事項如下：．．．（二）縣（市）建築管理。」次按建築法第27條規定：「非縣（局）政府所在地之鄉、鎮，適用本法之地區，非供公眾使用之建築物或雜項工作物，得委由鄉、鎮（縣轄市）公所依規定核發執照。鄉、鎮（縣轄市）公所核發執照，應每半年彙報縣（局）政府備案。」該條所稱「核發執照」之訂定意旨，包括核發建造執照、其後之施工管理及核發使用執照等事項。是各縣（局）政府自得視當地情形依建築法第27條規定，委由非縣（局）政府所在地之鄉、鎮（縣轄市）公所辦理上開事項業務。又該項事務因屬不同行政主體間之權限移轉，與行政程序法第15條規定之委任及委託有間，故縣政府如欲將部分建築管理業務授權由鄉（鎮、市）公所辦理，因屬不同地方自治團體（行政主體）間之權限移轉，屬「委辦」性質，自無行政程序法第15條規定之適用，至擬委辦予鄉（鎮、市）公所時，依地方制度法第2條第3款規定，應以法律、基於法律授權之中央法規或縣自治條例為依據，始得為之。

## Q09 | 大考中心的法律變身：訴願法 §10 條下受託 私法人之訴願管轄機關認定

教育部委託大學入學考試中心辦理大學入學考試事務，該中心所為之行政處分，當事人如有不服，應向何機關提起訴願？

- (A)行政院
- (B)教育部高等教育司
- (C)大學入學考試中心
- (D)教育部

### Legal Basis | 法條依據

🚩 訴願法10條：「依法受中央或地方機關委託行使公權力之團體或個人，以其團體或個人名義所為之行政處分，其訴願之管轄，向原委託機關提起訴願。」

### Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

訴願法10條，當事人如有不服，其訴願之管轄，向原委託機關提起訴願，故應向教育部提起訴願。

### ⚖️ Court View | 法院目前怎麼看？

#### 最高行政法院101年度判字第862號判決

原判決援引訴願法第10條規定「依法受『中央』或『地方機關』委託行使公權力之團體或個人，以其團體或個人名義所為之行政處分，其訴願管轄，向原委託機關提起訴願。」認考生不服財團法人大學入學考試中心（基金會）依考試簡章試場規則與違規處理辦法所為扣分行為，欲提起訴願時，應向「大學招生委員會聯合會」為

之，始符法制等語。惟並未敘明本件「大學招生委員會聯合會」將系爭大學考試業務委託「財團法人大學入學考試中心基金會」行使（辦理），何以應適用上開訴願法第10條規定，向原委託機關（即中央或地方機關）提起訴願，理由尚嫌不備。且縱認系爭處分應向「大學招生委員會聯合會」提起訴願，然教育部為大學法規定之中央主管機關，對大學招生（包括考試）事項，依法有輔導及監督之權責，業如上述；是系爭處分既經教育部自為訴願決定，與由「大學招生委員會聯合會」訴願決定效力應相同，基於程序經濟原則，亦無庸再由「大學招生委員會聯合會」重為訴願決定（本院94年度判字第787號、第1160號判決參照）。

## Q10 | 誰能拿到公法護身符？公務人員保障法之

### 「適用」與「準用」身分界線

下列何者適用或準用公務人員保障法之規定？

(A)政務官

(B)公營事業依法任用之人員

(C)公立學校聘任之教師

(D)民選公職人員

### Legal Basis | 法條依據

✦ 公務人員保障法102條1項：「下列人員準用本法之規定：

一、教育人員任用條例公布施行前已進用未經銓敘合格之公立學校職員。

二、私立學校改制為公立學校未具任用資格之留用人員。

三、公營事業依法任用之人員。

四、各機關依法派用、聘用、聘任、僱用或留用人員。

五、應各種公務人員考試錄取參加訓練之人員，或訓練期滿成績及格未獲分發任用之人員。」

### Analysis | 破題思路

(A)

91年度重上字第280號民事判決，公務人員任用法所指之公務人員，政務官不適用，故「政務官適用或準用公務人員保障法之規定」，為錯誤之敘述。

(B)

公務人員保障法102條1項，公營事業依法任用之人員，準用公務人員保障法之規定，為正確之敘述。

還願專用。嚴禁營利轉售

(C)

105年度訴字第380號民事判決，公立學校聘任之教師，因另有教師法之特別規範，並無公務人員保障法之適用，故「公立學校聘任之教師適用或準用公務人員保障法之規定」，為錯誤之敘述。

(D)

103年度裁字第1762號裁定，公務人員不包括民選公職人員，故「民選公職人員適用或準用公務人員保障法之規定」，為錯誤之敘述。

### 🏛️ Court View | 法院目前怎麼看？

#### 臺灣高等法院91年度重上字第280號民事判決

惟公務人員任用法施行細則第二條規定：本法所稱公務人員，指各機關組織法規中，除政務官及民選人員外，定有職稱及官等之文職人員，...，且行政法院五十年判字第七三號判例意旨略謂：「公務人員任用法所指之公務人員，與公務員服務法所指之公務員，其範圍原非一致。前者固於技術人員、教育人員、公營事業人員、派用聘用人員、雇員及政務官皆不適用，而後者則凡受有俸給之公務員均適用之，自不能以聘用人員不適用公務人員任用法，而即謂其亦應不適用公務員服務法。至聘用人員之給與，苟其薪給待遇實質上與一般公務人員之俸給無何差異，即不能僅以其名稱不同而認其性質亦不相類。」，又依司法院大法官會議釋字第二七號解釋謂：「...公營事業機關服務人員均適用公務員服務法，為該法第二十四條所明定，中央信託局係國營事業機關，其依法令在該局服務人員，自屬公務員服務法上之公務員，仍應受本院釋字第六號及第十一號解釋之限制。」，第七三號解釋亦謂：「依公司法組織之公營事業，縱於移轉民營時已確定其盈虧及一切權利義務之移轉日期，仍應俟移轉後之民股超過百分之五十以上時，該事業方得視為民營，尚未在實行交接以前，其原有依法令服務之人員，仍係刑法上之公務員」

#### 臺灣臺南地方法院105年度訴字第380號民事判決

還願專用。嚴禁營利轉售

次按「教師對主管教育行政機關或學校有關其個人之措施，認為違法或不當，致損其權益者，得向各級教師申訴評議委員會提出申訴」、「教師不願申訴或不服申訴、再申訴決定者，得按其性質依法提起訴訟或依訴願法或行政訴訟法或其他保障法律等有關規定，請求救濟」，教師法第29條第1項、第33條分別定有明文，準此，公立學校聘任之教師，因另有教師法之特別規範，並無公務人員保障法之適用，但公立學校對教師所為之考績評定，係基於公法上機關地位，對教師所為之公法上措施，教師如有不服，應適用教師法規定進行救濟，本件原告對本件被告包含校長及考績考核委員對其成績考核之程序（包含事實之認定）、結果，認為違法或不當，應向各級教師申訴評議委員會提出申訴，而原告亦已提出申訴，並遭駁回等情，有101年1月2日教育部中央教師申訴評議委員會申訴評議書1件在卷可佐（見本院補字卷第66至68頁），原告一再執被告等於處理原告成績考核過程有違背職務之行為，已屬無據。

#### 最高行政法院103年度裁字第1762號裁定

按公務人員保障法第3條規定：「本法所稱公務員，係指法定機關依法任用之有給專任人員及公立學校編制內依法任用之職員。前項公務人員不包括政務人員及民選公職人員。」依據該法主管機關公務人員保障暨培訓委員會91年1月3日公保字第9007239號函釋意旨，認為上開規定所稱依法任用之人員，係指依相關公務人員任用法律任用之現職人員而言，尚不包括軍職人員在內。

## Q11 | 沒錢寸步難行！給付行政下「預算依據」之憲法絕對保留與程序界限

關於給付行政之概念，下列敘述何者錯誤？

- (A)給付行政是指提供人民給付、服務或給與其他利益的行政作用
- (B)行政機關對於給付行政的實施有較大之選擇自由，得以公法型態或私法型態為之
- (C)凡是給付行政涉及金錢或財務給予者，縱無預算作為依據，亦得為給付行政
- (D)行政機關事後廢棄給付行政的具體處分時，應考量相對人的信賴利益

### Analysis | 破題思路

(A)

101年度上訴字第789號刑事判決，以滿足民生需求之重要職能，為維持、改善人民生活，而提供人民給付、服務等利益之給付行政行為，舉如：補貼獎勵、道路建設。

「提供人民給付、服務或給與其他利益的行政作用」，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故A不選。

(B)

95年度國字第10號民事判決，依行政行為選擇方式之自由，如行政機關選擇以公法型態為之，惟如行政機關選擇以私法方式為之，涉及行政私法之問題。

「給付行政的實施有較大之選擇自由，得以公法型態或私法型態」，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故B不選。

(C)

109年度簡字第25號判決，給付行政措施所受法律規範之密度，自較限制人民權益者寬鬆，通常祇須有國會通過之預算為依據，其措施之合法性即無疑義，然而給付行政亦非均可不受法律之控管，當給付行政措施涉及公共利益或實現人民基本權利之保障等重大事項者，當即應有法律或法律明確之授權作為依據。

「縱無預算作為依據，亦得為給付行政」為錯誤之敘述，而本題要選錯誤的，故選C。

(D)

98年度判字第1074號判決，公保優存要點，此係屬給付行政措施，公權力行使涉及人民信賴利益而有保護之必要者，不限於授益行政處分之撤銷或廢止，即行政法規之廢止或變更亦有其適用。

「廢棄給付行政的具體處分時，應考量相對人的信賴利益」，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故D不選。

## Court View | 法院目前怎麼看？

### 臺灣高等法院臺中分院101年度上訴字第789號刑事判決

又公務機關基於排除危害及維護安全之目的，所為對人民之權利、自由、財產加以干預、限制，或課予人民義務、負擔之干涉行政行為，固係居於統治權主體之地位所為行使公權力之行為；其本於現代民主國家積極主動提供人民最大服務與照顧，以滿足民生需求之重要職能，為維持、改善人民生活，而提供人民給付、服務等利益之給付行政行為，舉如：補貼獎勵、道路建設等，亦同屬基於國家、地方自治團體統治權作用之公權力行為。依地方制度法第2條第1款、第14條之規定，地方自治團體係指依該法實施地方自治，具公法人地位之團體，包括直轄市、縣、（省轄）市、鄉、鎮及縣轄市。

### 臺灣臺南地方法院95年度國字第10號民事判決

「公有公共設施」可解為由國家、地方自治團體或其他公法人管理，以供公共或公務目的使用之有體物或其他物之設備，目前各級政府機關就公共設施委託民間團體經營之類型中，其中包含相關設施委託私人經營管理型態，在典型給付行政所設置之設施，是否屬供公共或公務目的使用，依行政行為選擇方式之自由，如行政機關選擇以公法型態為之，無論該設施係供公務或公共目的使用，均屬國家賠償法第3條所稱之公有公共設施；惟如行政機關選擇以私法方式為之，除涉及行政私法之問題外，政府機關與利用人之關係應屬私法關係，應不認為該等設施屬國家賠償之公有公共設施，即使委託私人營運，私人亦不可能與利用人產生公法關係，此時應依私法範疇之侵權行為加以處理（法務部93年8月16日法律字第0930700390號函、法務部93年6月24日「諮商國家賠償法第3條規定公有公共設施之適用範圍」會議紀錄參照）。

### 臺灣新竹地方法院109年度簡字第25號判決

（三）按憲法所定人民之自由及權利範圍甚廣，凡不妨害社會秩序公共利益者，均受保障，惟並非一切自由及權利均無分軒輊受憲法毫無差別之保障。至何種事項應以法律直接規範或得委由命令予以規定，與所謂規範密度有關，應視規範對象、內容或法益本身及其所受限制之輕重而容許合理之差異，若僅屬執行法律之細節性、技術性次要事項，則得由主管機關發布命令為必要之規範，雖因而對人民產生不便或輕微影響，尚非憲法所不許。次按，公務人員與國家間雖屬公法上職務關係，服勤務為該公法上職務關係之核心內容，其由此所衍生而得享有之身分保障、俸給、服勤時間、休假制度、退休金請求等權利，為憲法第18條服公職權保障之核心範圍（司法院釋字第614號、第658號、第707號、785號等解釋參照），另就核心保障範圍外之權益事項，國家基於對人民之生存照顧義務，而採取諸如社會保險、社會救助、生活必需品之供給、舉辦職業訓練、給予經濟補助及提供文化服務等行政上措施，以改善社會成員之生存環境及生活條件，此即所謂「給付行政」措施之範疇。給付行政措施所受法律規範之密度，自較限制人民權益者寬鬆，通常祇須有國會通過之預算為依據，其措施之合法性即無疑義，且基於國家資源的有限性，立法者或



行政機關享有寬廣之立法或政策形成空間，於盱衡國家財政、社會發展、措施之迫切性與必要性等一切情事後，就給付之對象、項目、要件、範圍等予以規劃，以發揮社會形成的功能。而如果人民請求權之創設，係因職權命令、行政規則而來，基於拉丁法諺「有為重要行為之權者，自可為次要行為」之法理，於同一位階之法規範當亦可限縮或消滅該權利自明。然而給付行政亦非均可不受法律之控管，當給付行政措施涉及公共利益或實現人民基本權利之保障等重大事項者，當即應有法律或法律明確之授權作為依據（司法院釋字第443號、第707號解釋參照）。

#### 最高行政法院98年度判字第1074號判決

教育部早期為照顧現職所得及退休所得偏低之教育人員，在會商財政部等有關機關同意後，訂定發布公保優存要點，此係屬給付行政措施，且僅適用於特定族群，並無涉及公共利益之重大事項，依上說明，其受法律規範之密度，應較限制人民權益者寬鬆，故無以法律或法律授權之命令為依據之必要。惟經多年後，教育部考慮社會經濟狀況、財政收支情形與整體公益平衡原則，審酌得適用之對象、範圍及辦理優惠存款之額度，依權限修正該要點，以符合正當性與公平性，自無違反平等原則。...（五）公權力行使涉及人民信賴利益而有保護之必要者，不限於授益行政處分之撤銷或廢止，即行政法規之廢止或變更亦有其適用。行政法規公布施行後，制定或發布法規之機關依法定程序予以修改或廢止時，應兼顧規範對象信賴利益之保護，因為上開釋字第525號解釋在案；惟信賴保護之構成要件須符合（1）信賴基礎；（2）信賴表現；（3）信賴在客觀上值得保護等要件；上訴人主張長期以來信賴包含優惠存款在內之退撫制度，在公保優存要點第3點之1修正後，使上訴人客觀上具體表現其因信賴而生之實體法上利益受損害云云；惟查上訴人因新舊公保優存要點變更所受利息差額損害，並非當然屬於基於信賴而實際開始規劃其生活或財產之變動所受之損失，上訴人並未進一步證明其因信賴原公保優存要點規劃經濟活動而受有何損失，亦即未證明其有信賴表現，遽以新舊公保優存要點計算之利息差額作為信賴表現之損失，自嫌無據。

## Q12 | 機關內部的「法律說明書」：論解釋性行政規則之發布程式與法律定性

內政部就平均地權條例有關銷售預售屋書面契據不得轉讓之規定所為之統一解釋，其性質為何？

- (A)行政處分
- (B)行政計畫
- (C)行政指導
- (D)行政規則

### Legal Basis | 法條依據

✦ 行政程序法159條2項：「行政規則包括下列各款之規定：

- 一、關於機關內部之組織、事務之分配、業務處理方式、人事管理等一般性規定。
- 二、為協助下級機關或屬官統一解釋法令、認定事實、及行使裁量權，而訂頒之解釋性規定及裁量基準。」

### Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

行政程序法159條2項，內政部為協助下級機關或屬官統一解釋法令而訂頒之解釋性規定，應為解釋性「行政規則」。

## Q13 | 負擔、條件與保留廢止權之辨析：解析行政程序法 §93 條於補助款追回之應用

甲工廠向乙行政機關請領裝設先進環保設備之補助，乙機關慮及，若甲未將環保設備實際用於生產過程，得立即追回該補助，並避免因產生補償責任，乙機關應如何處置最為妥適？

- (A)直接作成發放補助之處分，並在確認甲未實際運用設備時，撤銷該行政處分
- (B)直接作成發放補助之處分，並在確認甲未實際運用設備時，廢止該行政處分
- (C)作成發放補助之處分，並於該處分中，附加「甲應將設備運用於生產過程」之附款；在確認甲未實際運用設備時，溯及廢止該行政處分
- (D)作成發放補助之處分，並於該處分中，附加「甲應將設備運用於生產過程」之附款，否則嗣後將向行政法院訴請返還該補助

### Legal Basis | 法條依據

✦ 行政程序法93條2項：「前項所稱之附款如下：

- 一、期限。
- 二、條件。
- 三、負擔。
- 四、保留行政處分之廢止權。
- 五、保留負擔之事後附加或變更。」

✦ 行政程序法127條1項：「授予利益之行政處分，其內容係提供一次或連續之金錢或可分物之給付者，經撤銷、廢止或條件成就而有溯及既往失效之情形時，受益人應返還因該處分所受領之給付。其行政處分經確認無效者，亦同。」

✦ 行政程序法127條3項：「行政機關依前二項規定請求返還時，應以書面行政處分確認返還範圍，並限期命受益人返還之。」

還願專用。嚴禁營利轉售

### Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

行政程序法93條2項、127條1項、3項，確認甲未實際運用設備時，溯及廢止該行政處分，受益人甲工廠應返還因該處分所受領之給付，乙行政機關應以書面行政處分確認返還範圍，並限期命甲工廠返還之，故C之處置最為妥適，而D的「否則嗣後將向行政法院訴請返還該補助」為錯誤之敘述。

## Q14 | 行政處分效力型態大點名：負擔、授益、身分創設與既有狀態確認

關於行政處分性質之敘述，下列何者正確？

- (A)判定役男甲體位為免役體位，係形成處分
- (B)核准外國人乙歸化為中華民國國民，係確認處分
- (C)任命丙為公務人員，係下命處分
- (D)撤銷丁建築執照發放，係形成處分

### Analysis | 破題思路

(A)

91年度判字第514號判決，判定役男體位，旨在確定役男服何種兵役，性質上屬「確認處分」，故「係形成處分」為錯誤之敘述。

還願專用。嚴禁營利轉售

(B)

93年度訴字第244號判決，行政機關基於法律授權，就申請人之身分、條件、資格證明等規範，其所為之准駁處分即為行政處分，依行政處分之類別上，乃屬「形成處分」，故「係確認處分」為錯誤之敘述。

(C)

臺北高等行政法院95年度訴字第920號判決，任用，行政機關具有用人權限，並透過任命處分，形成雙方權利義務關係；任免，對於所屬人員可經由被告所屬人事處作成任免之「形成處分」，故「係下命處分」為錯誤之敘述。

(D)

99年度訴更二字第32號判決，申請建築執照，「許可」是行政機關，就個別事件，廢棄原有之法律上禁止，容許相對人從事特定行為的「形成處分」，故「係形成處分」為正確之敘述。

## Court View | 法院目前怎麼看？

### 最高行政法院91年度判字第514號判決

查判定役男體位，旨在確定役男服何種兵役，性質上屬確認處分，而非授益處分，應與信賴保護利益無涉。且本件再審原告原即經國防部中央審查組判定為戊等役男體位，自始即未認定其為可服國民兵役之丙等體位役男，因再審被告所屬民雄鄉公所之疏失，誤以丙等體位通知再審原告，已如上述，則再審被告嗣發現錯誤，予以更正，乃係回復原來正確體位，並非先確定再審原告為丙等體位後，再將之撤銷，另判定為戊等體位，自無信賴保護原則之適用。再審原告以原判決有違信賴保護原則，而適用法規顯有錯誤云云，即不足取。其再審之訴顯無理由，應予駁回。

### 高雄高等行政法院93年度訴字第244號判決

(三)按就業服務法第四十八條第一項、第二項明文，及其施行細則第三條明定，授權中央主管機關依法頒布行政命令或規則辦法等規範該等作業程序，並依依法行政，然針對聘僱外國人之許可及管理辦法中，行政機關基於法律授權，就申請人之身分、條件、資格證明等規範，其所為之准駁處分即為行政處分。又行政審查在性質上屬於「內部審查」，範圍上及於合法性審查與妥當性審查（亦稱合目的性審查），…。行政機關受理人民（含機關、法人團體）申請許可案，依行政處分之類別上，乃屬「形成處分」，亦即對一個非經審查不得從事之行為所作成的同意為之的決定。而根據該行政處分對於原告產生「有利」或「不利」之法律效果，亦可稱為「授益處分」。

### 臺北高等行政法院95年度訴字第920號判決

次按公務人員任用法第4條規定：「各機關任用公務人員，應注意其品德及對國家之忠誠，其學識、才能、經驗及體格，應與擬任職務之種類職責相當。如係主管職務，並應注意其領導能力。」基此，行政機關具有用人權限，並透過任命處分，形成雙方權利義務關係。又公務人員考績法第14條第1項規定：「各機關對於公務人員之考績，應由主管人員就考績表項目評擬，遞送考績委員會初核，機關長官覆核。經由主管機關核定，送銓敘部銓敘審定。」故各機關對所屬人員得依其平日表現給予年終考績評等作為晉升或淘汰之依據或針對特定事件辦理專案考績給予所屬人員一次記2大過免職處分，達到獎優汰劣之目的。從而，對於公務人員的任免係屬行政機關之法定權限，與前揭銓敘部之「審定權」並無衝突或抵觸之處。(3)另依被告組織自治條例第7條規定：「各局、處、委員會及中心置局長、處長、主任委員及主任，承市長之命，分別掌理各該局、處、委員會及中心事務，並指揮監督所屬機關及員工。」被告人事處組織規程第2條及第3條分別規定：「臺北市政府人事處…，承市長之命，綜理處務，…」「本處設下列科、室分別掌理各有關事項：…二、第二科：掌理考試分發、『任免』、遷調…及其有關事項。」準此，被告對於所屬人員可經由被告所屬人事處作成「任免」之形成處分，其方式包含辦理專案考績一次記2大過免職處分。綜上，被告對於原告不僅有「任用權」，同時亦得依公務人員考績法

之規定，給予年終考績評等或針對違法特定事件辦理專案考績一次記2大過免職處分，此項「任免」權限與詮敘部之「審定權」並無衝突或抵觸。

#### 臺北高等行政法院99年度訴更二字第32號判決

「許可」是行政機關，就個別事件，廢棄原有之法律上禁止，容許相對人從事特定行為的形成處分。中央法規標準法第18條「各機關受理人民聲請許可案件適用法規時，除依其性質應適用行為時之法規外，如在處理程序終結前，據以准許之法規有變更者，適用新法規。但舊法規有利於當事人而新法規未廢除或禁止所聲請之事項者，適用舊法規」的規定，依法條文義解釋，如採狹義解釋僅指人民欲從事特定行為或活動須經行政機關加以許可始得為之而言（如申請建築執照或集會遊行之許可），則給付行政領域中，人民單純給付之申請或其他創設、變更、撤銷法律關係之申請，將難以界定是否屬人民聲請許可案件，為符合行政訴訟新制之精神，並與行政訴訟法第5條課予義務訴訟範圍得以一致，所謂「人民聲請許可案件」，宜採廣義解釋以符合法律整體解釋精神。又中央法規標準法第18條是在規範各機關受理人民聲請許可案件的法規適用，若非屬或類似人民聲請許可案件，或性質上應適用行為時之法規時，當然沒有應該援引適用新法規的問題。

## Q15 | 是「法規天生限制」還是「機關後天加料」？行政處分附款與法定內容限制之劃界

下列何者非屬行政處分之附款？

- (A) 交通主管機關核發小型車普通駕駛執照，註記不得駕駛聯結車、大客車與大貨車
- (B) 建築主管機關核發建築執照，註記須向機關提供合法廢土棄置場所之證明後，始得開工
- (C) 農業主管機關核定同意農地設置太陽能發電設備，但核定書內敘明，若未依核定計畫內容設置，得廢止之
- (D) 主管機關核准餐廳經營之營業許可，但註明須設置噪音污染防治設備

還願專用。嚴禁營利轉售

## Legal Basis | 法條依據

✦ 行政程序法93條2項：「前項所稱之附款如下：

- 一、期限。
- 二、條件。
- 三、負擔。
- 四、保留行政處分之廢止權。
- 五、保留負擔之事後附加或變更。」

## Analysis | 破題思路

(A)

小型車普通駕駛執照，註記不得駕駛聯結車、大客車與大貨車，為「法定義務之註記」。

(B)

行政程序法93條2項2款，須向機關提供合法廢土棄置場所之證明後，始得開工，為「條件」之附款。

(C)

行政程序法93條2項4款，若未依核定計畫內容設置得廢止之，為「保留行政處分之廢止權」之附款。

(D)

行政程序法93條2項3款，須設置噪音污染防治設備，為「負擔」之附款。

還願專用。嚴禁營利轉售

## Q16 | 行政契約救濟與組織法之終極合流：高權干涉、行政主體同一、山地原住民區自治

人民如與A直轄市之原住民族事務主管機關締結行政契約後，下列何機關於該行政契約關係外行使公權力，有補償規定之適用？

- (A)內政部
- (B)A直轄市地政主管機關
- (C)原住民族委員會
- (D)A直轄市山地原住民區之區公所

### Legal Basis | 法條依據

✦ 行政程序法145條1項：「行政契約當事人之一方為人民者，其締約後，因締約機關所屬公法人之其他機關於契約關係外行使公權力，致相對人履行契約義務時，顯增費用或受其他不可預期之損失者，相對人得向締約機關請求補償其損失。但公權力之行使與契約之履行無直接必要之關聯者，不在此限。」

✦ 地方制度法83-2條1項：「直轄市之區由山地鄉改制者，稱直轄市山地原住民區（以下簡稱山地原住民區），為地方自治團體，設區民代表會及區公所，分別為山地原住民區之立法機關及行政機關，依本法辦理自治事項，並執行上級政府委辦事項。」

### Analysis | 破題思路

- (A) 內政部，為公法人「中華民國」所屬之機關。

(B)

109年度簡上字第43號判決，行政程序法145條1項，該等規定之適用，自締約機關與行使公權力者之其他機關屬同一公法人者為限。

締約機關「A直轄市之原住民族事務主管機關」與行使公權力者之其他機關「A直轄市地政主管機關」為同一公法人「A直轄市」所屬之機關。

(C)

原住民族委員會，為公法人「中華民國」所屬之機關。

(D)

A直轄市山地原住民區之區公所，為地方自治團體，依本法辦理自治事項，本身為一個獨立的公法人。

### ⚖️ Court View | 法院目前怎麼看？

#### 高雄高等行政法院109年度簡上字第43號判決

按行政程序法第145條第1項規定：「行政契約當事人之一方為人民者，其締約後，因締約機關所屬公法人之其他機關於契約關係外行使公權力，致相對人履行契約義務時，顯增費用或受其他不可預期之損失者，相對人得向締約機關請求補償其損失。但公權力之行使與契約之履行無直接必要之關聯者，不在此限。」係就人民與行政機關締結行政契約後發生締約機關以外之其他機關於契約關係外行使公權力，致人民因履約而顯增費用或受其他不可預期之損失，締約雙方之權利義務應如何調整，所為規範，故該等規定之適用，自締約機關與行使公權力者之其他機關屬同一公法人者為限。

## Q17 | 公法合意的「法定死穴」：行政契約無效事由之體系與效力阻斷

關於行政契約之法律效果，下列敘述何者錯誤？

- (A)行政機關與人民以行政契約約定國家考試之錄取決定，該行政契約無效
- (B)行政契約若締約機關欠缺事務管轄權而構成重大明顯之瑕疵者，該行政契約無效
- (C)行政機關與人民締結之行政契約，未依行政程序法規定以書面方式為之，該行政契約無效
- (D)行政機關與人民締結侵害第三人權利之行政契約，若締約前未經該第三人書面同意，該行政契約無效

### Legal Basis | 法條依據

✦ 行政程序法135條：「公法上法律關係得以契約設定、變更或消滅之。但依其性質或法規規定不得締約者，不在此限。」

✦ 行政程序法141條1項：「行政契約準用民法規定之結果為無效者，無效。」

✦ 行政程序法141條2項：「行政契約違反第一百三十五條但書或第一百三十八條之規定者，無效。」

✦ 行政程序法142條：「代替行政處分之行政契約，有下列各款情形之一者，無效：

- 一、與其內容相同之行政處分為無效者。
- 二、與其內容相同之行政處分，有得撤銷之違法原因，並為締約雙方所明知者。
- 三、締結之和解契約，未符合第一百三十六條之規定者。
- 四、締結之雙務契約，未符合第一百三十七條之規定者。」

✦ 行政程序法111條：「行政處分有下列各款情形之一者，無效：

- 一、不能由書面處分中得知處分機關者。
- 二、應以證書方式作成而未給予證書者。
- 三、內容對任何人均屬不能實現者。
- 四、所要求或許可之行為構成犯罪者。
- 五、內容違背公共秩序、善良風俗者。
- 六、未經授權而違背法規有關專屬管轄之規定或缺乏事務權限者。
- 七、其他具有重大明顯之瑕疵者。」

✦ 行政程序法139條：「行政契約之締結，應以書面為之。但法規另有其他方式之規定者，依其規定。」

✦ 民法73條：「法律行為，不依法定方式者，無效。但法律另有規定者，不在此限。」

✦ 行政程序法140條1項：「行政契約依約定內容履行將侵害第三人之權利者，應經該第三人書面之同意，始生效力。」

### Analysis | 破題思路

(A)

行政程序法135條、141條1項、2項，原則上公法上法律關係得以契約設定，惟例外依其性質不得締約時，則不得以契約為之，而契約約定考試之錄取決定，其準用民法規定之結果應為無效，故「該行政契約無效」為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故A不選。

(B)

行政程序法111條、142條，代替行政處分之行政契約，有與其內容相同之行政處分為無效之情形，則該行政契約為無效，而行政處分有缺乏事務權限之情形時為無效，故「該行政契約無效」為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故B不選。



(C)

行政程序法141條1項、139條、民法73條，行政契約之締結，應以書面為之，若不依法定方式者，準用民法73條規定之結果為無效者，其效力為無效，故「該行政契約無效」為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故C不選。

(D)

93年度訴字第4027號判決，行政程序法140條1項，應經該第三人書面之同意，始生效力，故若締約前未經該第三人書面同意，該行政契約僅對第三人尚不生效力而已，而非無效，故為錯誤之敘述，而本題要選錯誤的，故選D。

## Court View | 法院目前怎麼看？

### 臺北高等行政法院93年度訴字第4027號判決

按行政程序法第140條第1項之規定須經原告同意始生效力，惟在原告未同意前，該契約亦僅對原告不生效力而已，並非無效，對被告間仍屬有效，本件迄今，被告尚未對原告主張該契約對原告發生效力，自無原告若不尋求判決確認即將受到不利益之效果之情形，殊無所謂即受確認判決之法律上利益可言。從而原告之訴，依其所訴之事實，既欠缺權利保護之必要即無確認訴訟之利益，在法律上為無理由，揆之首揭法條規定及說明，自應以判決駁回之。至原告請求將本件送請前司法院大法官吳庚就專業法律問題表示意見部分，本院認無必要且與本件判決結果無影響，爰不送請表示意見，附予敘明。

## Q18 | 行政罰責任個數與競合：一行為不二罰、數行為併罰、作為與不作為義務衝突

甲使用特定建築物經營商業，違反建築法中建築物不得變更使用之法定義務，同時甲所經營之商業項目，未向主管機關申領營利事業登記證，也違反商業登記法中商業登記之作為義務。就甲於本案所應受之行政罰，下列敘述何者正確？

(A) 本案共存在兩項違法行為，應依建築法與商業登記法分別裁處行政罰

(B) 本案僅存在單一違法行為，屬於想像競合從一重處斷，故應以建築法裁處行政罰

(C) 本案僅存在單一違法行為，不作為義務應優先於作為義務，故應以建築法裁處行政罰

(D) 本案僅存在單一違法行為，主要違法目的在於違規經營商業，故應以商業登記法裁處行政罰

## Legal Basis | 法條依據

✦ 行政罰法25條：「數行為違反同一或不同行政法上義務之規定者，分別處罰之。」

✦ 建築法73條2項：「建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第九條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照。但建築物在一定規模以下之使用變更，不在此限。」

✦ 建築法91條1項1款：「有左列情形之一者，處建築物所有權人、使用人、機械遊樂設施之經營者新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止其使用。必要時，並停止供水供電、封閉或命其於期限內自行拆除，恢復原狀或強制拆除：

一、違反第七十三條第二項規定，未經核准變更使用擅自使用建築物者。」



✦ 商業登記法31條：「未經設立登記而以商業名義經營業務或為其他法律行為者，商業所在地主管機關應命行為人限期辦妥登記；屆期未辦妥者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並得按次處罰。」

## Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

行政罰法25條，違反「建築法中建築物不得變更使用」之法定義務，與違反「商業登記法中商業登記」之作為義務，共存在「兩項」違法行為，應分別裁處行政罰。

## 🏠 Court View | 法院目前怎麼看？

### 臺中高等行政法院98年度訴字第204號判決

本件兩造之爭點為：(三)原告倘有前揭2違章行為，而分別違反建築法第73條第2項及第77條第1項規定，則被告依建築法第91條第1款及第2款規定，僅處以1行為之最低罰鍰6萬元，是否適法？...七、又按「建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第九條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照。．．．」、「建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全。」、「有左列情形之一者，處建築物所有權人、使用人、機械遊樂設施之經營者新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，．．．一違反第73條第2項規定，未經核准變更使用擅自使用建築物者。二未依第77條第1項規定維護建築物合法使用與其構造及設備安全者。」固分別為建築法第73條第2項、第77條第1項、第91條第1項第1款及第2款所明定。...。惟被告原處分係記載原告有上開2違章行為，而處以罰鍰及限期改善，然並未記載係對原告何一違章行為予以裁罰或合併處罰，且原告如有2違章行為，依行政罰法第25條規定：「數行為違反同一或不同行政法上義務之規定者，分別處罰之。」(被告稱因原告有上開2違章行為，而合併處罰，同卷89頁言詞辯論筆錄)，被告對原告2違章行為予以合併處罰，亦有違該規定

，是本件原處分僅有上開之記載，自無從依其記載之內容，認定是否已合法定之要件，並據以區別2違章行為被告各為如何之處分，及判斷其已否正確適用法律，自有違誤。

## 💡 立法者的 OS

### 行政罰法25條

行為人所為數個違反行政法上義務之行為，若違反數個不同之規定，或數行為違反同一之規定時，與前條單一行為之情形不同，為貫徹個別行政法規之制裁目的，自應分別處罰。此與司法院釋字第503號解釋「一事不二罰」之意旨並不相違。例如：原申請經營開設之租賃仲介行，經查獲其經營旅館業務，該行為本係違反商業登記法第八條第三項及第三十三條第一項之規定；又因該租賃仲介行另將建築物隔間裝潢改為套房，掛出套房出租招牌，並置有「敬請顧客先行付房租」告示，顯然已達變更建築物使用之程度，其行為另違反建築法第七十三條及第九十條之規定。按依商業登記法第八條第三項及第三十三條第一項規定之處罰要件為經營商業登記範圍以外之業務，而建築法第七十三條及第九十條則以變更建築物使用執照之用途為構成處罰之要件，二者處罰之違法行為並非相同，故應分別依商業登記法第八條第三項、第三十三條第一項及建築法第七十三條、第九十條規定予以處罰。

## Q19 | 打破刑法總則的「共犯分流」：行政罰法

### s14 條「單一行為人模式」

關於行政罰與刑罰之敘述，下列何者錯誤？

- (A)與刑法有別，行政罰法對於共同違法行為，並不區分共同正犯、教唆或幫助者
- (B)行為非出於故意或過失者，不予處罰，過失行為之處罰，以有特別規定者為限
- (C)不得因不知法律或法規而免除刑事或行政處罰責任。但按其情節，得減輕或免除其刑或處罰

(D)行政罰法以處罰違反行政法上義務為限

## Legal Basis | 法條依據

✿ 行政罰法14條1項：「故意共同實施違反行政法上義務之行為者，依其行為情節之輕重，分別處罰之。」

✿ 行政罰法7條1項：「違反行政法上義務之行為非出於故意或過失者，不予處罰。」

✿ 行政罰法8條：「不得因不知法規而免除行政處罰責任。但按其情節，得減輕或免除其處罰。」

✿ 行政罰法4條：「違反行政法上義務之處罰，以行為時之法律或自治條例有明文規定者為限。」

## Analysis | 破題思路

(A)

行政罰法14條1項，行政罰法對於共同違法行為，不區分共同正犯、教唆或幫助，而是依其行為情節之輕重分別處罰，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故A不選。

(B)

行政罰法7條1項，非出於故意或過失者，不予處罰，惟未規定「過失行為之處罰，以有特別規定者為限」為錯誤之敘述，而本題要選錯誤的，故選B。

(C)

行政罰法8條，不得因不知法律免除行政處罰，但按其情節得減輕，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故C不選。

還願專用。嚴禁營利轉售

(D)

行政罰法4條，違反行政法上義務，以行為時法律有明文規定者為限，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故D不選。

## 💡 立法者的 OS

行政罰法14條1項

一、本條係行政法上共同違法之規定，不採刑法有關教唆犯、幫助犯之概念，此因行政罰之不法內涵及非難評價不若刑罰，且為避免實務不易區分導致行政機關裁罰時徒生困擾之故。所謂「故意共同實施」，係指違反行政法上義務構成要件之事實或結果由二以上行為人故意共同完成者而言。又第一項所稱「情節之輕重」，係指實施違反行政法上義務行為其介入之程度及其行為可非難性之高低等因素。

二、又本條係規定行為主體外部之共同實施，在二個以上之自然人間，不生解釋疑義，然於以私法人作為處罰對象之情形，係指二以上不同之私法人（處罰主體）共同實施違反行政法上義務之行為，或私法人與該私法人以外之第三人共同實施違反行政法上義務之行為而言。故僅係基於受處罰主體私法人之內部關係者（如私法人之機關或職員），並不在本條所規定之範圍內。亦即本條所稱之「共同實施」，係指義務主體與該義務主體以外之第三人共同違反行政法上之義務，並不包括義務主體與該義務主體內部之成員共同違反行政法上義務之情形。

行政罰法4條

一、依法始得處罰，為民主法治國家基本原則之一，對於違反社會性程度輕微之行為，處以罰鍰、沒入或其他種類行政罰，雖較諸對侵害國家、社會公益等科以刑罰之行為情節輕微，惟本質上仍屬對於人民自由或權利之不利處分，其應適用處罰法定主義，仍無不同。為使行為人對其行為有所認識，進而擔負其在法律上應有之責任，自應以其違反行政法上義務行為時之法律有明文規定者為限，爰予明定。

還願專用。嚴禁營利轉售

## Q20 | 公物身分的「誕生與解構」：公物之所有權

### 歸屬與不經指定之「事實公用」

關於公物，下列敘述何者錯誤？

- (A) 公物之所有權人得為私人
- (B) 公物得依事實行為而提供公用
- (C) 公務所必需之公物，得為行政執行之標的物
- (D) 公物得為自然山域或水域

### Legal Basis | 法條依據

✦ 行政執行法26條：「關於本章之執行，除本法另有規定外，準用強制執行法之規定。」

✦ 強制執行法122-3條1項：「債務人管有之公用財產，為其推行公務所必需或其移轉違反公共利益者，債權人不得為強制執行。」

### Analysis | 破題思路

(A)

111年度訴字第419號判決，人民所有之土地設定為公物，欠缺權源，已形成特別犧牲，並應給予補償，故「所有權人得為私人」為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故A不選。

(B)

114年度訴字第166號判決，土地成為道路供公眾通行歷數十年已成為公共用物，故「得依事實行為而提供公用」為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故B不選。

還願專用。嚴禁營利轉售

(C)

行政執行法26條、強制執行法122-3條1項，為其推行公務債權人不得為強制執行，故「公物得為行政執行之標的物」為錯誤之敘述，而本題要選錯誤的，故選C。

(D)

114年度訴字第143號判決，河川公地為公有公物，故「公物得為自然山域或水域」為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故D不選。

### 🏛️ Court View | 法院目前怎麼看？

#### 臺北高等行政法院111年度訴字第419號判決

又憲法法庭111年憲判字第15號判決，係針對59年2月9日修正公布之農田水利會組織通則第11條第2項前段規定：「原提供為水利使用之土地，應照舊使用」（109年7月22日制定公布之農田水利法第11條第1項規定：「本法施行前提供農田水利會水利使用之土地，應照舊使用。」意旨相同），而宣示：「其應照舊使用之土地，如屬人民所有，而未以租用、價購或其他方式取得權源，因其已形成個人之特別犧牲，即應依法徵收，給予相當之補償，並於3年內擬定徵收補償相關計畫，籌措財源，俾於合理期限內逐步完成徵收補償，始符憲法第15條保障人民財產權之意旨。」其判決理由並進一步闡述：「國家將人民所有之土地設定為公物，要求所有權人須容忍其土地供公共使用，致人民就該土地無從自由使用收益，基於法治國家之要求，應具備設定公物關係之權源，若欠缺權源，因其已形成個人之特別犧牲，即應依法徵收，並給予相當之補償，始符憲法第15條保障人民財產權之意旨。」等語。

#### 臺中高等行政法院高等庭114年度訴字第166號判決

復按改制前最高行政法院45年判字第8號判例：「行政主體得依法律規定或以法律行為，對私人之動產或不動產取得管理權或他物權，使該項動產或不動產成為他有公物，以達行政之目的。此際該私人雖仍保有其所有權，但其權利之行使，則應受限制，不得與行政目的相違反。本件土地成為道路供公眾通行，既已歷數十年之久，

還願專用。嚴禁營利轉售

自應認為已因時效完成而有公用地役關係之存在。此項道路之土地，即已成為他有公物中之公共用物。原告雖仍有其所有權，但其所有權之行使應受限制，不得違反供公眾通行之目的。」

#### 臺中高等行政法院高等庭114年度訴字第143號判決

系爭使用許可處分之權利義務具一身專屬性；河川公地為公有公物，河川公地之使用乃公物之利用關係。依上揭水利法第78條之1第4款及河川管理辦法第34條規定，河川公地之使用應向河川管理機關申請許可，河川管理機關在一定條件下亦得撤銷許可，此項許可與撤銷，性質上為河川管理機關基於公法上地位，就河川公地之使用所為之行政處分，河川公地之利用關係顯屬公法上之許可使用關係。而依上開河川管理辦法第31條第1項、第2項規定：「(第1項)河川公地同一地點有二人以上申請使用，且書件齊全者，依下列規定定其優先順序：一、收件在先者。二、送達日期相同不能分別先後者，以抽籤決定之。(第2項)前項行為屬種植使用時，在原許可使用人死亡後6個月內，如原許可使用人之配偶及年滿16歲之直系血親過半數共同推具申請資格者提出申請時為最優先。」

## Q21 | 行政程序的「各自表述」：單獨代理原則與特別授權之權限邊界

關於行政程序法之代理人規定，下列敘述何者錯誤？

(A)代理權之授與，及於該行政程序有關之全部程序行為。但申請之撤回，非受特別授權，不得為之

(B)代理人有二人以上者，為避免個別代理行為之矛盾產生，故必須以共同代理方式為之

(C)代理人與當事人間有基於信任之契約關係，故代理人經本人同意後，始得委任他人為複代理人

(D)代理權不因本人死亡或其行政程序行為能力喪失而消滅，法定代理有變更或行政機關經裁併或變更者亦同

### Legal Basis | 法條依據

✦ 行政程序法24條3項：「代理權之授與，及於該行政程序有關之全部程序行為。但申請之撤回，非受特別授權，不得為之。」

✦ 行政程序法25條1項：「代理人有二人以上者，均得單獨代理當事人。」

✦ 行政程序法25條3項：「代理人經本人同意得委任他人為複代理人。」

✦ 行政程序法26條：「代理權不因本人死亡或其行政程序行為能力喪失而消滅。法定代理有變更或行政機關經裁併或變更者，亦同。」

### Analysis | 破題思路

(A)

行政程序法24條3項，申請之撤回，非受特別授權，不得為之，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故A不選。

(B)

行政程序法25條1項，代理人有二人，均得單獨代理當事人，故「必須以共同代理方式」，為錯誤之敘述，而本題要選錯誤的，故選B。

(C)

行政程序法25條3項，代理人經本人同意後，始得委任他人為複代理人，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故C不選。

(D)

行政程序法26條，代理權不因本人死亡而消滅，行政機關經裁併亦同，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故D不選。

## Q22 | 法效果與物理變動的分水嶺：行政處分之規制性與行政事實行為

下列何者非屬行政處分？

(A)交通警察在十字路口以手勢指揮交通

(B)海巡人員以向海面開槍之方式，命越界捕魚之船隻退離

(C)道路管理機關在既成道路上鋪設柏油

(D)衛生主管機關以通知單要求特定人於指定日期，讓公務員進入其住居所噴灑藥劑，撲滅病媒蚊

### Legal Basis | 法條依據

✳ 行政程序法92條1項：「本法所稱行政處分，係指行政機關就公法上具體事件所為之決定或其他公權力措施而對外直接發生法律效果之單方行政行為。」

### Analysis | 破題思路

(A)

106年度交上字第57號判決，因交通警察之指揮交通，係對在場之用路人依此一特徵而可確定其範圍之人所為，故屬「一般處分」為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故A不選。

(B)

108年度訴字第1491號判決，故意未經許可進入臺灣地區限制水域從事漁撈行為，對原告即系爭船舶之船長裁處罰鍰之「原處分」為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故B不選。

(C)

113年度訴字第651號判決，鋪設柏油性質上屬公法性質的行政事實行為，為錯誤之敘述，而本題要選錯誤的，故選C。

(D)

111年度簡字第41號判決，主動清除病媒孳生源之行政法上義務，為受主管機關採行措施之「行政處分」，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故D不選。

### 🏛️ Court View | 法院目前怎麼看？

#### 高雄高等行政法院106年度交上字第57號判決

行政程序法第92條定有明文。按交通警察在交岔路口，一般係向在場之眾多用路人以手勢為前進或停止通行之指揮，因交通警察之指揮交通，係對在場之用路人依此一特徵而可確定其範圍之人所為，故屬行政程序法第92條第2項前段所規定之一般處分。由於事實上不可能在各個交岔路口，隨時皆派遣交通警察在場指揮交通，交通主管機關遂依規定設置依時間變換顏色之交通燈號，以機械作用管制交通。用路人應依燈號之指示前進或停止通行，其情形一如交通警察在場指揮，故以變換燈號之機械作用指揮交通，其法律性質亦為行政程序法第92條第2項前段所規定，對「雖非特定，而依一般性特徵可得確定其範圍」之相對人所為之對人一般處分（陳敏著「交通標誌之法律問題」，當代公法新論（中）第188-189頁參照）。

#### 臺北高等行政法院108年度訴字第1491號判決



原告並表示「我因為進入臺灣限制水域捕魚，被帶回問筆錄，……，海巡艇臨檢當時，船正在進行拖網作業，……被扣留是因為我從事非法漁業行為、塗抹、隱蔽船名。……查獲當時，該網次漁獲30 0公斤……」等語（見原處分卷第15-17頁偵詢筆錄），自堪信為真實。又大陸船舶越界捕漁，影響海域資源，衡之可利用船舶之雷達系統功能標註相關外界線，原告身為船長，負責系爭船舶的安全及管理，職司指揮監督全體船員，綜理航行及漁撈作業，對航經海域之相關公告及法規應有認知等節，被告認為爭船舶故意未經許可進入臺灣地區限制水域從事漁撈行為，對原告即系爭船舶之船長裁處罰鍰160萬元，洵然有據，核未違反比例原則，亦無裁罰處分未記載理由之違反法定程式情形

#### 臺北高等行政法院高等庭113年度訴字第651號判決

結果除去請求權可作為公法上一般給付訴訟之請求權，應具備下列要件：1. 須被告機關之行政行為（包括行政處分或其他高權行為）違法，或行為時合法，後來因法律變更而成為違法者；2. 直接侵害人民之權益。3. 該侵害之狀態繼續存在，且有除去回復至行政行為前狀態之可能。4. 被害人對於損害之發生無重大過失（最高行政法院109年度上字第900號判決意旨參照）。又行政機關在私有土地上鋪設柏油之行為，乃係出於高權之行使，性質上屬公法性質的行政事實行為，且已影響土地所有權圓滿之狀態。故依前述說明，土地所有權人如認其財產權行政機關在其地上鋪設柏油而受到侵害，基於憲法第15條保障人民財產權之意旨，除得依民法第767條第1項請求普通法院除去侵害外（司法院釋字第758號解釋意旨參照），亦得依公法上結果除去請求權，向行政法院提起一般給付訴訟。

#### 臺灣臺南地方法院111年度簡字第41號判決

又主管機關依上開規定所採行之通知或公告，前者係針對通知相對人課予主動清除病媒孳生源之行政法上義務，性質上係就通知相對人之權利義務發生規制作用之下命處分；後者則透過一般性特徵可得確定其範圍，即其誡命對象為主管機關轄內公、私場所之所有人、管理人、使用人，對象核為可得特定，而其誡命之事項內容為該等人員應主動清除病媒孳生源，核屬具體明確，性質上係屬行政程序法第92條

第2項前段之對人一般處分。又人民受主管機關依上開規定所採行措施之行政處分，依傳染病防治法第25條第2項規定意旨，發生須依主管機關所通知或公告之內容，主動清除病媒孳生源之行政法上義務，倘人民違反上開行政法上義務者，主管機關即得依同法第70條第1項第1款規定予以裁罰。

## Q23 | 司法倒數的「保護緩衝期」：從寄存之日起算十日看人民爭訟權益之保障

依行政程序法、訴願法及行政訴訟法規定，關於寄存送達之敘述，下列何者正確？

- (A) 行政程序及訴願之寄存送達，自送達完畢時即發生效力
- (B) 訴願及行政訴訟之寄存送達，自送達完畢時即發生效力
- (C) 行政程序及訴願之寄存送達，自寄存之日起，經10日發生效力
- (D) 訴願及行政訴訟之寄存送達，自寄存之日起，經10日發生效力

### Legal Basis | 法條依據

✦ 行政程序法74條1項：「送達，不能依前二條規定為之者，得將文書寄存送達之地方自治或警察機關，並作送達通知書兩份，一份黏貼於應受送達人住居所、事務所、營業所或其就業處所門首，另一份交由鄰居轉交或置於該送達處所信箱或其他適當位置，以為送達。」

✦ 訴願法47條3項：「訴願文書之送達，除前二項規定外，準用行政訴訟法第六十七條至第六十九條、第七十一條至第八十三條之規定。」

✦ 行政訴訟法73條1項：「送達不能依前二條規定為之者，得將文書寄存於送達地之自治或警察機關，並作送達通知書二份，一份黏貼於應受送達人住居所、事務所或營業所門首，一份交由鄰居轉交或置於應受送達人之信箱或其他適當之處所，以為送達。」

還願專用。嚴禁營利轉售

還願專用。嚴禁營利轉售

✦ 行政訴訟法73條3項：「寄存送達，自寄存之日起，經十日發生效力。」

## Analysis | 破題思路

(A)(B)(D)

訴願法47條3項、行政訴訟法73條1項、3項，自寄存之日起，經十日發生效力，為正確之敘述。

(C)

釋字第797號，行政程序法74條1項，以行政文書依法寄存送達完畢時作為發生送達效力之時點，整體而言，其程序規範尚屬正當，故「行政程序經10日發生效力」，為錯誤之敘述。

## 🏠 Court View | 法院目前怎麼看？

### 釋字第797號【行政文書寄存送達案】

行政程序法第74條關於寄存送達於依法送達完畢時即生送達效力之程序規範，尚屬正當，與憲法正當法律程序原則之要求無違。  
...（同法第72條及第73條規定參照）均無法完成送達時之輔助、替代手段。而不問一般送達、補充送達或留置送達，均以使應受送達人可得知悉應受送達文書為發生送達效力之要件，作為前開送達方式之輔助、替代手段之寄存送達，亦使應受送達人處於可得知悉之地位，即為已足。寄存送達先以送達通知書之黏貼與轉交、置放作為送達方式，再將文書寄存於應送達處所之地方自治、警察機關或郵務機構，便利人民隨時就近前往領取，藉以實現送達目的。...，判斷應受送達之住、居所、事務所、營業所或就業處所而為送達。因上開應送達處所係應受送達人日常生活活動之處所，寄存送達以黏貼與轉交、置放之送達方式，已使應受送達人處於可得知悉之狀態。經綜合考量寄存送達乃一般送達、補充送達或留置送達之輔助、替代手段、行政行為之多樣性、人民受合法通知權之保障，以及行政效能之公共利益等因

素，足認系爭規定所設寄存送達之程序及方式，尚稱嚴謹、妥適，則以行政文書依法寄存送達完畢時作為發生送達效力之時點，整體而言，其程序規範尚屬正當，與憲法正當法律程序原則之要求無違，自不能僅因系爭規定未以寄存日起經一定時間始生送達效力，即謂寄存送達之程序規範有不正當之處。

系爭規定所設寄存送達之程序及方式，固符合憲法正當法律程序原則之要求，已如上述，然為求人民基本權利獲得更為妥適、有效之保障，相關機關亦非不得參酌民事訴訟法第138條第2項及行政訴訟法第73條第3項等規定，就寄存送達之生效日或其救濟期間之起算另為設計，併此指明。

## Q24 | 陽光法案的「主動出擊」：資訊公開之主動與被動雙軌制與人民知的情權

關於政府資訊公開法規定之敘述，下列何者正確？

(A)與人民權益攸關之施政、措施及其他有關之政府資訊，不待國民申請，原則上即應主動公開

(B)國民申請提供政府資訊，以主張或維護其法律上利益有必要者為要件

(C)國民申請提供之政府資訊包含有侵害個人隱私之部分時，全部均不得提供

(D)申請提供政府資訊遭到拒絕而不服者，不得單獨就該拒絕決定提起行政救濟

## Legal Basis | 法條依據

✦ 政府資訊公開法6條：「與人民權益攸關之施政、措施及其他有關之政府資訊，以主動公開為原則，並應適時為之。」

✦ 政府資訊公開法7條1項：「下列政府資訊，除依第十八條規定限制公開或不予提供者外，應主動公開：

一、條約、對外關係文書、法律、緊急命令、中央法規標準法所定之命令、法規命令及地方自治法規。



二、政府機關為協助下級機關或屬官統一解釋法令、認定事實、及行使裁量權，而訂頒之解釋性規定及裁量基準。

三、政府機關之組織、職掌、地址、電話、傳真、網址及電子郵件信箱帳號。

四、行政指導有關文書。

五、施政計畫、業務統計及研究報告。

六、預算及決算書。

七、請願之處理結果及訴願之決定。

八、書面之公共工程及採購契約。

九、支付或接受之補助。

十、合議制機關之會議紀錄。」

✦ 政府資訊公開法9條1項：「具有中華民國國籍並在中華民國設籍之國民及其所設立之本國法人、團體，得依本法規定申請政府機關提供政府資訊。持有中華民國護照僑居國外之國民，亦同。」

✦ 政府資訊公開法18條1項：「政府資訊屬於下列各款情形之一者，應限制公開或不予提供之：

一、經依法核定為國家機密或其他法律、法規命令規定應秘密事項或限制、禁止公開者。

二、公開或提供有礙犯罪之偵查、追訴、執行或足以妨害刑事被告受公正之裁判或有危害他人生命、身體、自由、財產者。

三、政府機關作成意思決定前，內部單位之擬稿或其他準備作業。但對公益有必要者，得公開或提供之。

四、政府機關為實施監督、管理、檢（調）查、取締等業務，而取得或製作監督、管理、檢（調）查、取締對象之相關資料，其公開或提供將對實施目的造成困難或妨害者。

五、有關專門知識、技能或資格所為之考試、檢定或鑑定等有關資料，其公開或提供將影響其公正效率之執行者。

六、公開或提供有侵害個人隱私、職業上秘密或著作權人之公開發表權者。但對公益有必要或為保護人民生命、身體、健康有必要或經當事人同意者，不在此限。

七、個人、法人或團體營業上秘密或經營事業有關之資訊，其公開或提供有侵害該個人、法人或團體之權利、競爭地位或其他正當利益者。但對公益有必要或為保護人民生命、身體、健康有必要或經當事人同意者，不在此限。

八、為保存文化資產必須特別管理，而公開或提供有減失或減損其價值之虞者。

九、公營事業機構經營之有關資料，其公開或提供將妨害其經營上之正當利益者。但對公益有必要者，得公開或提供之。」

✦ 政府資訊公開法20條：「申請人對於政府機關就其申請提供、更正或補充政府資訊所為之決定不服者，得依法提起行政救濟。」

## Analysis | 破題思路

(A)

政府資訊公開法6條，與人民權益攸關之施政，主動公開為原則，為正確之敘述。

(B)

政府資訊公開法9條1項，具國籍並在中華民國設籍之國民，得依本法規定申請政府機關提供政府資訊，並未「以主張或維護其法律上利益有必要者為要件」為錯誤之敘述。

(C)

政府資訊公開法18條1項，政府資訊公開或提供有侵害個人隱私、職業上秘密，應限制公開，故「全部均不得提供」為錯誤之敘述。

(D)

政府資訊公開法20條，申請人對於政府機關就其申請提供之決定不服者，得依法提起行政救濟，故「不得單獨就該拒絕決定提起行政救濟」為錯誤之敘述。

## 立法者的 OS

### 政府資訊公開法6條

舉凡與人民權益攸關之施政、措施及其他有關之政府資訊，因對人民之影響至深且鉅，故有主動公開之必要，並為使人民得以適時掌握資訊，避免資訊過時，故明定應適時為之。惟該政府資訊如有第18條第1項各款應限制公開或不予提供之情形者，仍應依該條規定辦理。

### 政府資訊公開法20條

一、資訊公開與限制公開之範圍互為消長，如不公開之範圍過於擴大，勢將失去本法制定之意義；惟公開之範圍亦不宜影響國家整體利益、公務之執行及個人之隱私等，爰於本條第一項列舉政府資訊限制公開或提供之範圍，以資明確。

二、依法核定為國家國家機密或依法律、法規命令規定應秘密之事項，符合法律保留原則，本為本法之特別規定，爰明定應限制公開或不予提供，以利適用，爰為第一項第一款之規定。

三、與犯罪之偵查、追訴、執行有關之政府資訊如予公開或提供，勢必影響犯罪之偵查、追訴、執行，甚或使犯罪者逍遙法外，影響社會治安甚巨，故此等資訊自應限制公開或不予提供；又政府資訊之公開或提供，足以妨害刑事被告受公正之裁判者，亦應限制公開或不予提供；另政府資訊之公開或提供，有危害他人生命、身體、自由或財產者，為保護該個人之權益計，亦不應將此等資訊加以公開或提供，爰為第一項第二款之規定。

四、政府機關之內部意見或與其他機關間之意見交換等政府資訊，如予公開或提供，因有礙該機關最後決定之作成且易滋困擾，例如對有不同意見之人員加以攻訐，自應限制公開或不予提供，惟對公益有必要者，自不在限制範圍之列，以求平衡，爰為第一項第三款之規定。

五、政府機關為實施監督、管理、檢（調）查或取締等業務，而取得或製作其監督、管理、檢（調）查或取締對象之相關資料，如該資料之公開或提供將對實施目的造成困難或妨害者（例如：將造成取締之困難），該等政府資訊自應限制公開或不予提供，爰為第一項第四款之規定。

六、有關專門知識、技能或資格所為之考試、檢定或鑑定，係基於專業能力所為之判斷，屬價值判斷之一環，該等資訊之公開或提供將影響其公正效率之執行者，自應限制公開或不予提供，爰為第一項第五款之規定。

七、政府資訊之公開或提供有侵害個人隱私、執業中所獲得之秘密或著作權人之公開發表權時，為保護當事人的權益，該等政府資訊自應限制公開或不予提供；惟對公益有必要或為保護人民生命、身體、健康有必要或經當事人同意公開或提供者，自不在限制範圍之列，爰為第一項第六款之規定。

八、個人、法人或團體營業上秘密或其經營事業有關之資訊，該等資訊之公開或提供有侵害該個人、法人或團體之權利、競爭地位或其他正當利益時，為保護當事人之權益，該等政府資訊亦應限制公開或不予提供；惟如對公益有必要或為保護人民生命、身體、健康有必要者，自不在限制範圍，爰為第一項第七款之規定。

九、政府資訊中涉及文化資產者，其公開或提供與保存文化資產之目的相違背時，應予限制公開或不予提供，爰為第一項第八款之規定。

十、政府機關於職權範圍內作成或取得公營事業機構經營之有關資料，往往涉及其營業上秘密，其公開或提供將妨害其經營上之正當利益者，自應限制公開或不予提供；惟對公益有必要者，則不在限制範圍，爰為第一項第九款之規定。

十一、政府資訊中若含有限制公開或不予提供之部分，並非該資訊之全部內容者，政府機關應將限制公開或不予提供之部分除去後，僅公開或提供其餘部分，此即所謂之「分離原則」，爰為第二項之規定。

## Q25 | 拘提與到場的殊途同歸：行政執行法 §17 條 下「自行到場」之管收合法性

有關行政執行法對於將公法上金錢給付義務人予以管收之要件，下列何者錯誤？

- (A) 執行機關不得在命義務人提供擔保、限期履行前，即向法院聲請裁定管收
- (B) 管收要件包含義務人有逃匿之虞，或其可能履行義務，卻故不履行，或為虛偽財產報告或拒絕報告
- (C) 義務人經通知不到場而受拘提後，才能予以管收，如義務人自行到場接受調查者，不得予以管收
- (D) 義務人如因管收難以維持家計或罹患疾病無法治療，應准予停止管收，無須聲請法院裁定

### Legal Basis | 法條依據

✦ 行政執行法17條3項：「義務人經行政執行處依第一項規定命其提供相當擔保，限期履行，屆期不履行亦未提供相當擔保，有下列情形之一，而有強制其到場之必要者，行政執行處得聲請法院裁定拘提之：

- 一、顯有逃匿之虞。
- 二、經合法通知，無正當理由而不到場。」

✦ 行政執行法17條5項：「義務人經拘提到場，行政執行官應即訊問其人有無錯誤，並應命義務人據實報告其財產狀況或為其他必要調查。」

✦ 行政執行法17條6項：「行政執行官訊問義務人後，認有下列各款情形之一，而有管收必要者，行政執行處應自拘提時起二十四小時內，聲請法院裁定管收之：

- 一、顯有履行義務之可能，故不履行。
- 二、顯有逃匿之虞。
- 三、就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事。

還願專用。嚴禁營利轉售

四、已發見之義務人財產不足清償其所負義務，於審酌義務人整體收入、財產狀況及工作能力，認有履行義務之可能，別無其他執行方法，而拒絕報告其財產狀況或為虛偽之報告。」

✦ 行政執行法17條7項：「義務人經通知或自行到場，經行政執行官訊問後，認有前項各款情形之一，而有聲請管收必要者，行政執行處得將義務人暫予留置；其訊問及暫予留置時間合計不得逾二十四小時。」

✦ 行政執行法17條12項：「拘提、管收，除本法另有規定外，準用強制執行法、管收條例及刑事訴訟法有關訊問、拘提、羈押之規定。」

✦ 管收條例7條：「債務人、擔保人或其他依法得管收之人有左列情形之一者，不得管收；其情形發生於管收後者，應停止管收：

- 一、因管收而其一家生計有難以維持之虞者。
- 二、懷胎六月以上或生產後二月未滿者。
- 三、現罹疾病，恐因管收而不能治療者。」

### Analysis | 破題思路

(A)

行政執行法17條3項，屆期不履行亦未提供相當擔保，有強制其到場之必要，得聲請法院裁定拘提，5項，命義務人據實報告，6項，有管收必要，聲請法院裁定管收之。

「不得在命供擔保、限期履行前，即向法院聲請裁定管收」，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故A不選。

(B)

行政執行法17條6項，管收要件包含有履行義務之可能、逃匿之虞、拒絕報告、為虛偽之報告，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故B不選。

還願專用。嚴禁營利轉售

(C)

111年度抗字第185號民事裁定，義務人到場說明，相對人(法務部行政執行署臺中分署)確有管收事由，且有管收之必要聲請於法有據，應予准許。

行政執行法17條7項，義務人自行到場，行政執行官認有聲請管收必要，得將義務人暫予留置，「如義務人自行到場接受調查者，不得予以管收」為錯誤之敘述，而本題要選錯誤的，故選C。

(D)

行政執行法17條12項，拘提、管收準用管收條例之規定，管收條例7條，債務人因管收難以維持家計或罹患疾病無法治療，其情形發生於管收後者，應停止管收，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故D不選。

## Court View | 法院目前怎麼看？

### **臺灣高等法院111年度抗字第584號民事裁定**

按94年6月22日修正前行政執行法第17條第1項、第2項分別規定…。現行條文除保留第1項規定外，其第7項關於義務人經通知或自行到場後予以管收之規定，雖僅規定「經行政執行官訊問後，認有前項各款情形之一，而有聲請管收必要者，行政執行處得將義務人暫予留置；其訊問及暫予留置時間合計不得逾24小時」，但現行條文係依司法院大法官會議釋字第588號解釋而為修正，旨在加強人身自由之保障，並符合比例原則，管收之要件較修正前更為嚴格；管收既係強制執行之最後手段，則行政執行機關依現行規定聲請法院裁定管收，尤應先踐行上述程序，即非先命義務人提供擔保，限期履行，不得逕聲請法院裁定管收（最高法院103年度台抗字第1043號裁定意旨參照）。又按法院裁定管收義務人，必須行政執行機關執有相當證據，足認義務人確有履行能力而故不履行，或就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事，且有管收必要之情形，始符合上開行政執行法所定之管收要件。執行機關就此應盡舉證責任（最高法院99年度台抗字第644號裁定參照）。

### **臺灣高等法院臺中分院111年度抗字第185號民事裁定**

文軒公司欠繳系爭稅款，於96年移送執行後，抗告人徐文軒公司之實際負責人，於111年4月26日到場說明，經相對人(法務部行政執行署臺中分署)詢問抗告人能否就處分系爭房地財產或系爭3600萬元或處分移轉「壹咖啡」商標所有權及對加盟廠商應盡權利義務之財產範圍內履行本件稅捐罰鍰或提供擔保繳納？抗告人均明確表示「沒有辦法」等語（見系爭執行卷三第867-869頁），應認已有屆期不履行亦未提供擔保之情事。而文軒公司有前述顯有履行義務之可能故不履行，及就應供強制執行之財產有隱匿、處分並有虛偽報告財產狀況之情事，詳如前述，本件確有行政執行法第17條第6項第1、3、4款之管收事由，且有管收之必要，相對人之聲請於法有據，應予准許。

## Q26 | 拆違建的「代勞經濟學」：代替性行為義務

### 之代履行要件與費用預納機制

A公司在其工廠旁違法搭建了一處臨時倉庫，經主管機關查獲後，依建築法相關規定，命令A公司於30日內自行拆除該違建，並於處分書中明確告知逾期不履行將予以強制執行。A公司逾期未拆除，且未提出任何異議。關於此類行為義務之強制執行，下列敘述何者正確？

- (A)主管機關可直接派員拆除該違建，並將拆除費用加計行政成本全額向A公司追償
- (B)主管機關應先對A公司處以怠金，若A公司仍不履行，方可進行強制拆除
- (C)主管機關應向法院聲請強制執行，由法院執行處負責拆除該違建
- (D)主管機關可委託第三人代為拆除該違建，並將拆除費用估計後，命A公司預先繳納

### Legal Basis | 法條依據

✦ 行政執行法27條1項：「依法令或本於法令之行政處分，負有行為或不行為義務，經於處分書或另以書面限定相當期間履行，逾期仍不履行者，由執行機關依間接強制或直接強制方法執行之。」

✦ 行政執行法29條1項：「依法令或本於法令之行政處分，負有行為義務而不為，其行為能由他人代為履行者，執行機關得委託第三人或指定人員代履行之。」

✦ 行政執行法29條2項：「前項代履行之費用，由執行機關估計其數額，命義務人繳納；其繳納數額與實支不一致時，退還其餘額或追繳其差額。」

### Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

行政執行法27條1項，負有行為義務，逾期仍不履行，執行機關，29條1項，得委託第三人或指定人員代履行之，2項，代履行之費用由執行機關估計數額，命義務人繳納。

## Q27 | 公法法律關係的「驗身證明」：國籍、公法

### 人會員與公用地役之確認適格

下列何者非屬確認訴訟之標的？

- (A)確認道路交通安全規則無效
- (B)確認當事人是否屬於某公法人之會員
- (C)確認某筆土地是否具有公用地役關係
- (D)確認當事人是否具有中華民國國籍

### Legal Basis | 法條依據

✦ 行政訴訟法6條1項：「確認行政處分無效及確認公法上法律關係成立或不成立之訴訟，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之。其確認已執行而無回復原狀可能之行政處分或已消滅之行政處分為違法之訴訟，亦同。」

### Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

112年度抗字第299號裁定，法規非法律關係之本身，不得以其存否為確認訴訟之標的，故「確認道路交通安全規則無效」非屬確認訴訟之標的，故選A。

**最高行政法院112年度抗字第299號裁定**

次按行政訴訟法第6條第1項規定：「確認行政處分無效及確認公法上法律關係成立或不成立之訴訟，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之。其確認已執行而無回復原狀可能之行政處分或已消滅之行政處分為違法之訴訟，亦同。」可知，行政訴訟法所規範得提起確認訴訟之訴訟類型有「確認行政處分無效訴訟」、「確認公法上法律關係成立或不成立訴訟」及「確認已執行而無回復原狀可能之行政處分或已消滅之行政處分為違法訴訟」3種。其中，確認行政處分無效、確認已執行而無回復原狀可能或已消滅之行政處分違法之訴訟，係以行政處分為對象提起之確認訴訟類型，若行政機關所為並非行政處分，自不得提起此等確認訴訟。而所稱公法上法律關係，乃指特定生活事實之存在，因法規之規範效果，在兩個以上權利主體間所產生之權利義務關係，或產生人對權利客體間之利用關係。又行政法上法律關係之成立有直接基於法規規定者，亦有因行政處分、行政契約或事實行為而發生者。至法規、行政行為及事實均非法律關係之本身，故皆不得以其存否為確認訴訟之標的。故若當事人提起之確認訴訟非屬上開法定之類型，即應認其起訴係不備要件。

## Q28 | 教師解聘救濟：憲法法庭111年憲判字第11號

依司法實務見解，公立大學依法解聘其教師甲，並議決1年不得聘任為教師。甲對上開解聘及1年不得聘任為教師不服而提起救濟時，下列敘述何者正確？

- (A) 甲就解聘，得向教育部提起訴願
- (B) 甲就解聘，得以教育部為被告，提起確認聘任法律關係存在之訴
- (C) 甲就1年不得聘任為教師，得提起確認聘任法律關係存在之訴
- (D) 甲就1年管制期間，得以教育部為原處分機關，提起訴願

### Analysis | 破題思路

(A)

111年憲判字第11號，不續聘教師，其法效僅係使教師在原受聘學校不予聘任，性質核係單純基於聘任契約所為之意思表示，故「得向教育部提起訴願」為錯誤之敘述。

(B)

111年憲判字第11號，確認聘任法律關係存在之訴，應以「公立大學」，而非「教育部」。

(C)

111年度上字第889號判決，具有剝奪教師受聘於全國其他各級學校之職業選擇自由而影響其工作權之效力，已非教師與原聘任學校間之聘任契約法律關係範圍內事項，核為單方具有規制效力之「行政處分」。

1年不得聘任為教師，故「確認聘任法律關係存在之訴」為錯誤之敘述。



(D)

111年度上字第889號判決，公立大學將教育部對此作成之核准決定轉知教師知悉，教師對終身不得聘任為教師之處分，循序提起行政訴訟，應以核准之主管教育行政機關教育部為被告。

得以教育部為原處分機關提起訴願，為正確之敘述，故選D。

 Court View | 法院目前怎麼看？

#### 111年憲判字第11號【公立大學就不續聘教師之再申訴決定提起行政訴訟案】

大學聘用教師之自主權既受大學自治之保障，是各大學得與符合聘用資格之特定教師訂立聘任契約，以形成雙方間之權利義務關係，並於聘約期限屆至時決定是否繼續聘任。惟國家為保障大學教師之工作權益與生活，以提升教師專業地位，對大學與其所屬教師之權利義務，以及教師之解聘、不續聘、停聘等之要件與程序等事項，於教育人員任用條例及教師法均有明文規範，並藉須經主管機關核准，予以監督〔教育人員任用條例第31條、103年1月8日修正公布教師法（下稱103年教師法）第14條、108年6月5日修正公布教師法（下稱現行教師法）第14條至第16條、第18條及第22條規定參照〕。就大學於聘約期限屆至時是否續聘教師而言，大學法第19條規定：「大學除依教師法規定外，……得基於學術研究發展需要，另定教師……不續聘之規定，……並納入聘約。」又依103年教師法第14條第1項第14款及第2項規定（現行教師法為第16條），大學就是否不續聘教師，須經學校教師評審委員會審議，以認定教師是否有不續聘原因，並報主管教育行政機關核准，予以不續聘；而此等規範內容，涉及各大學與教師於聘約期限屆至時，是否不再繼續成立新的聘約關係，且應為各大學與所聘教師間聘任契約之內容。是各大學依據具此等規範內容之聘約約定，不續聘教師，其法效僅係使教師在原受聘學校不予聘任，性質核係單純基於聘任契約所為之意思表示，雖對教師之工作權益有重大影響，惟尚與大學為教師資格之審定，係受委託行使公權力，而為行政處分之性質（司法院釋字第462號解釋參照）有別。

#### 最高行政法院111年度上字第889號判決

102年7月10日修正公布前之教師法，對於因法定事由經解聘、停聘或不續聘之教師，不得聘任為教師，此乃依當時教師法第14條第3項規定之法律效果。102年7月10日教師法修正公布後，方有經教評會議決並報教育部核准後，不得聘任為教師之規定。依教師法（按指103年1月8日修正公布，下同）第14條第2項及第3項規定，教師有同條第1項第13款「行為違反相關法令，經有關機關查證屬實」規定之情事，經教評會議決解聘或不續聘者，除情節重大者外，應併審酌案件情節，議決1年至4年不得聘任為教師，並報主管教育行政機關核准；教師有教師法第14條第1項第1款至第12款或同條第2項後段情事之一者，不得聘任為教師；已聘任者，應報主管教育行政機關核准後，予以解聘、停聘或不續聘。是依上開規定所為不得聘任為教師之行為，具有剝奪教師受聘於全國其他各級學校之職業選擇自由而影響其工作權之效力，已非教師與原聘任學校間之聘任契約法律關係範圍內事項，核為單方具有規制效力之行政處分。公立大學以其所屬教師具有教師法第14條第1項各款之事由，而本於契約當事人地位對其為解聘之意思表示者，僅得使該教師退出該校之現任教職。惟為維護學生受教育之權利，對於具有教師法第14條第1項第1款至第12款情事，或因第13款事由且情節重大遭解聘之教師，立法者認其已不適任於教職，乃以教師法第14條第3項之規定，使其終身不得再任教師，以維護公益。至於立法者基於比例原則之考量，就因教師法第14條第1項第13款之事由遭到解聘，除情節重大者外，規定教評會應併審酌案件情節，依教師法第14條第2項規定，議決教師1年至4年不得聘任為教師，報經教育部核准。關於此在一定期間不得聘任為教師之決定，其性質及職權機關，經本院110年度上字第19號有關教師與公立大學間之同類案件受理庭，依大法庭提案程序提具徵詢書徵詢他庭，獲覆各庭同意其所採意見而得一致之見解，認其性質「具有剝奪教師受聘於全國其他各級學校之職業選擇自由而影響其工作權之效力，已非教師與原聘任學校間之聘任契約法律關係範圍內事項，核為單方具有規制效力之行政處分」，「又其中應經學校教評會於解聘事件中併同議決1年至4年不得聘任為教師之程序，乃基於學校對該解聘事實情節最熟知之考量，惟學校於教評會議決後仍應將議決報請主管教育行政機關核准，其旨即因此已非單純屬於原學校與其聘任教師間之聘任法律關係，而是使教師於一定期間內全面退出教師職場，限制教師工作權之重大事項，故賦予主管教育行政機關統籌對學校之議決為實質審查以作

成最終決定之權責。是以，主管教育行政機關依教師法第14條第2項規定對公立大學教評會議決教師於一定期間不得聘任為教師之核准，始對該教師產生於一定期間內不得聘任為教師之規制效果。從而，公立大學將教育部對此作成之核准決定轉知教師知悉，教師對該1年不得聘任為教師之處分，循序提起行政訴訟，應以核准之主管教育行政機關教育部為被告」。本件關於終身不得聘任處分與該案（一定期間不得聘任）為同類爭議，自應依照前揭已經本院統一之見解，認為主管教育行政機關依教師法第14條第3項規定對公立大學教評會議決教師依同條第1項第13款規定解聘，且情節重大，終身不得聘任為教師之核准，始對該教師產生終身不得聘任為教師之規制效果。從而，公立大學將教育部對此作成之核准決定轉知教師知悉，教師對終身不得聘任為教師之處分，循序提起行政訴訟，應以核准之主管教育行政機關教育部為被告。

## Q29 | 契約變奏曲的訴訟終局：情事變更拒絕調整時「一般給付訴訟」之訴訟適格

人民甲與行政機關締結行政契約後，甲因情事變更，向行政機關申請調整契約內容，但行政機關函覆「本案不符情事重大變更之法定要件」，拒絕調整。依最高行政法院實務見解，甲應如何提起行政訴訟？

- (A)提起課予義務訴訟，請求法院判令行政機關作成同意調整之行政處分
- (B)提起一般確認訴訟，請求法院為確認情事變更法律關係存在之判決
- (C)提起一般給付訴訟，請求法院判令行政機關為同意調整之意思表示
- (D)提起撤銷訴訟，並請求法院為增、減給付或變更其他原有效果之判決

### Legal Basis | 法條依據

✿ 行政程序法147條1項：「行政契約締結後，因有情事重大變更，非當時所得預料，而依原約定顯失公平者，當事人之一方得請求他方適當調整契約內容。如不能調整，得終止契約。」

✿ 行政程序法147條3項：「第一項之請求調整或終止與第二項補償之決定，應以書面敘明理由為之。」

### Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

110年度上字第352號判決，不符合情事重大變更，而拒絕調整契約內容，則上訴人提起一般給付訴訟，請求法院判令被上訴人同意調整契約內容，故選C。

### ⚖️ Court View | 法院目前怎麼看？

#### 最高行政法院110年度上字第352號判決

按行政程序法第147條第1項、第3項規定：「（第1項）行政契約締結後，因有情事重大變更，非當時所得預料，而依原約定顯失公平者，當事人之一方得請求他方適當調整契約內容。如不能調整，得終止契約。……（第3項）第1項之請求調整或終止……，應以書面敘明理由為之。」契約當事人之一方，依前開規定請求他方（相對人）調整契約內容，他方不為協議，或協議不成，則請求為調整之當事人，得向行政法院提起一般給付訴訟，請求法院判決相對人為同意調整之意思表示，以完成契約之變更，如經法院判決勝訴確定，即視為相對人已為同意之意思表示。本件上訴人於109年3月31日依前開規定，以書面向被上訴人請求調整契約內容，被上訴人以109年6月5日函，函覆認上訴人所舉事證，不符合情事重大變更，而拒絕調整契約內容，則上訴人提起一般給付訴訟，請求法院判令被上訴人同意調整契約內容，程序上並無不合。

## Q30 | 金字塔訴訟的「專業入場券」：行政訴訟律師強制代理

下列何者非屬應適用律師強制代理之事件或案件？

- (A) 高等行政法院管轄之環境保護、土地爭議之第一審通常訴訟程序事件
- (B) 都市計畫審查程序事件
- (C) 人民聲請憲法法庭就法規範及裁判憲法審查之案件
- (D) 人民向最高行政法院提起之事件

### Legal Basis | 法條依據

✦ 行政訴訟法49-1條1項：「下列各款事件及其程序進行中所生之其他事件，當事人應委任律師為訴訟代理人：

- 一、高等行政法院管轄之環境保護、土地爭議之第一審通常訴訟程序事件及都市計畫審查程序事件。
- 二、高等行政法院管轄之通常訴訟程序上訴事件。
- 三、向最高行政法院提起之事件。
- 四、適用通常訴訟程序或都市計畫審查程序之再審事件。
- 五、適用通常訴訟程序或都市計畫審查程序之聲請重新審理及其再審事件。」

✦ 憲法訴訟法8條1項：「當事人得委任律師為訴訟代理人；除有下列情形之一者外，言詞辯論期日，應委任律師為訴訟代理人：

- 一、當事人或其代表人、法定代理人具有法官、律師或第三項第一款得為訴訟代理人之資格。
- 二、第六條第二項所稱相對人。
- 三、被彈劾人已選任辯護人。」

## Analysis | 破題思路

(A)

行政訴訟法49-1條1項1款，高等行政法院管轄之環境保護、土地爭議之第一審通常訴訟程序事件，當事人應委任律師為訴訟代理人。

(B)

行政訴訟法49-1條1項2款，都市計畫審查程序事件，當事人應委任律師為訴訟代理人。

(C)

憲法訴訟法8條1項，就法規範及裁判憲法審查之案件，當事人得委任律師為訴訟代理人，為「非屬應適用律師強制代理之事件」。

(D)

行政訴訟法49-1條1項3款，向最高行政法院提起之事件，當事人應委任律師為訴訟代理人。

## Q31 | 審判權移送新制與最高法院指定管轄之路徑

關於審判權之爭議，下列敘述何者正確？

- (A) 行政法院對人民提起之行政訴訟事件，認無審判權而屬於刑事法院之審判權時，得逕予裁定駁回其訴
- (B) 民事法院認無審判權移送行政法院，行政法院亦認其無審判權，應聲請大法官就審判權爭議作成統一解釋
- (C) 依現行制度，難以區分法律關係屬於公法或私法時，當事人可以合意定審判權之歸屬，受理之法院受其拘束，不得再依職權審查審判權之有無

(D)行政法院受理訴訟認無審判權，以裁定移送民事法院審理，該裁定確定後，民事法院認其亦無審判權，應裁定停止訴訟程序，並向最高法院請求指定有審判權之管轄法院

## Legal Basis | 法條依據

✦ 法院組織法7-3條1項：「法院認其無審判權者，應依職權以裁定將訴訟移送至有審判權之管轄法院。但其他法律另有規定者，不在此限。」

✦ 法院組織法7-4條1項：「前條第一項移送之裁定確定時，受移送法院認其亦無審判權者，應以裁定停止訴訟程序，並向其所屬審判權之終審法院請求指定有審判權之管轄法院。但有下列情形之一者，不在此限：

一、原法院所屬審判權之終審法院已認原法院無審判權而為裁判。

二、民事法院受理由行政法院移送之訴訟，當事人合意願由民事法院為裁判。」

✦ 法院組織法7-4條2項：「前項所稱終審法院，指最高法院、最高行政法院或懲戒法院第二審合議庭。」

✦ 法院組織法7-5條3項：「受移送法院或經前條第一項之終審法院指定之有審判權法院所為裁判，上級審法院不得以無審判權為撤銷或廢棄之理由。」

## Analysis | 破題思路

(A)

法院組織法7-3條1項，法院認其無審判權者，應依職權以裁定將訴訟移送至有審判權之管轄法院，故「得逕予裁定駁回其訴」為錯誤之敘述。

(B)

法院組織法7-4條1項、2項，向其所屬審判權之終審法院請求指定有審判權之管轄法院

還願專用。嚴禁營利轉售

，其指最高法院、最高行政法院，故「應聲請大法官就審判權爭議作成統一解釋」為錯誤之敘述。

(C)

法院組織法7-4條1項2款，民事法院受理行政法院移送之訴訟時，當事人合意願由民事法院裁判，法未明文承認當事人可以合意審判權歸屬，故「當事人可以合意定審判權之歸屬，受理之法院受其拘束，不得再依職權審查審判權之有無」為錯誤之敘述。

(D)

法院組織法7-4條1項、2項，向其所屬審判權之終審法院請求指定有審判權之管轄法院，其指最高法院，為正確之敘述，故選D。

## Q32 | 手滑撥錯錢：公法上不當得利返還請求權

因作業疏失，甲行政機關誤撥付款項予乙人民，下列敘述何者正確？

(A)甲對乙雖因撥款錯誤之行政事實行為而取得對乙之不當得利返還請求權，但尚不得作成下命處分命乙返還

(B)甲得作成書面行政處分，限期命乙返還

(C)甲機關得逕行移送行政執行

(D)甲須向普通法院訴請乙返還所受領之不當得利

## Legal Basis | 法條依據

✦ 行政程序法127條1項：「授予利益之行政處分，其內容係提供一次或連續之金錢或可分物之給付者，經撤銷、廢止或條件成就而有溯及既往失效之情形時，受益人應返還因該處分所受領之給付。其行政處分經確認無效者，亦同。」

✦ 行政程序法127條3項：「行政機關依前二項規定請求返還時，應以書面行政處分確認返還範圍，並限期命受益人返還之。」

還願專用。嚴禁營利轉售

✦ 行政程序法127條4項：「前項行政處分未確定前，不得移送行政執行。」

## Analysis | 破題思路

(A)(B)(D)

114年度上字第742號判決，金錢給付，非以授益處分為其法律上原因，因此所生之不當得利返還問題即無行政程序法第127條之適用。

行政機關無從依該條第3項規定，以行政處分方式命受益人返還，而應回歸前述一般公法上不當得利返還機制之法理，提起一般給付訴訟。

不得作成下命處分命乙返還，為正確之敘述，故選A。

甲得作成書面行政處分，限期命乙返還，為錯誤之敘述。

須提起「一般給付訴訟」，故應非「向普通法院」訴請返還，為錯誤之敘述。

(C)

行政程序法127條4項，行政處分未確定前，不得移送行政執行，故「得逕行移送行政執行」為錯誤之敘述。

## 🏛️ Court View | 法院目前怎麼看？

### 最高法院114年度上字第742號判決

次按「無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。」民法第179條定有明文。而公法上不當得利返還請求權，係於公法之法律關係中，受損害者對無法律上之原因而受領給付者，請求其返還所受利益之權利，以調整當事人間不當之損益變動。公法上不當得利，雖然

實定法尚無一般性規定，然為公法上固有之法理，可與民法不當得利制度相比擬。參酌前揭民法第179條規定，公法上不當得利返還請求權需具備以下要件：1.須為公法關係之爭議；2.須有一方受利益，他方受損害；3.利益與受損害之間須有直接因果關係；4.受利益係無法律上原因等要件，始足當之（司法院釋字第515號解釋意旨參照）。再按行政程序法第127條第1項至第3項規定：「（第1項）授予利益之行政處分，其內容係提供一次或連續之金錢或可分物之給付者，經撤銷、廢止或條件成就而有溯及既往失效之情形時，受益人應返還因該處分所受領之給付。其行政處分經確認無效者，亦同。（第2項）前項返還範圍準用民法有關不當得利之規定。（第3項）行政機關依前2項規定請求返還時，應以書面行政處分確認返還範圍，並限期命受益人返還之。」係針對經由授益處分而提供金錢或可分物之給付而規範之特殊公法上不當得利返還請求權類型。是若行政機關提供之金錢給付，非以授益處分為其法律上原因，因此所生之不當得利返還問題即無行政程序法第127條之適用，行政機關無從依該條第3項規定，以行政處分方式命受益人返還，而應回歸前述一般公法上不當得利返還機制之法理，提起一般給付訴訟，請求裁判以取得執行名義；行政機關如以函文通知受益人於一定期限內繳還所受領款項，僅係通知受益人履行返還義務，該函文並未對外直接發生確認返還範圍並限期命受益人返還之法律效果，核屬觀念通知，而非行政處分，受益人對之提起撤銷訴訟，即屬不備起訴要件，應予駁回。

## Q33 | 「合法犧牲」與「不法侵害」的楚河漢界：

### 損失補償之特別犧牲本質與國賠之分野

人民於下列何種情形之下得請求損失補償？

- (A)被違規行駛之垃圾車撞傷
- (B)因為跌入未設警告標誌之馬路坑洞而受傷
- (C)因為搭乘臺灣鐵路公司之火車出軌而受傷
- (D)主管機關依法徵收前已埋設地下設施物，妨礙土地所有權人之權利行使



## Legal Basis | 法條依據

✿ 國家賠償法2條2項：「公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任。公務員怠於執行職務，致人民自由或權利遭受損害者亦同。」

✿ 國家賠償法3條1項：「公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家應負損害賠償責任。」

## Analysis | 破題思路

(A)

國家賠償法2條2項，被違規行駛之垃圾車撞傷，應屬「損害賠償責任」，而非「損失補償」。

(B)

114年度國字第20號民事判決，原告不慎踩入系爭坑洞因而受有系爭傷害，致其身體受損害，是原告依國賠法第3條第1項規定，請求被告負賠償責任，於法即屬有據。

國家賠償法3條1項，跌入未設警告標誌之馬路坑洞受傷，應屬「損害賠償責任」，而非「損失補償」。

(C)

113年度勞上字第23號民事判決，駕駛系爭列車執行職務，並非處於國家機關之地位，行使統治權作用之公法行為，核與被上訴人以公務員身分執行公法上之職務，致侵害他人權利之情形有別，應依民事法律關係賠償乘客。

火車出軌而受傷，應屬「民事損害賠償責任」，而非「損失補償」。

還願專用。嚴禁營利轉售

(D)

101年度台上字第728號民事判決，釋字第440號，主管機關對於既成道路或都市○○道路用地，在依法徵收或價購以前埋設地下設施物妨礙土地權利人對其權利之行使，致生損失，形成其個人特別之犧牲，應享有受相當補償。

徵收前已埋設地下設施物，妨礙土地所有權人之權利行使，得請求損失補償。

## 🏛️ Court View | 法院目前怎麼看？

### 臺灣臺南地方法院100年度國字第7號民事判決

次按公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，「國家」應負損害賠償責任。公務員怠於執行職務，致人民自由或權利遭受損害者亦同。國家賠償法第2條第2項定有明文；又依國家賠償法第2條第2項請求損害賠償者，以該公務員「所屬機關」為賠償義務機關，復為同法第9條第1項所明定。是人民以公務員執行職務行使公權力，因故意或過失不法侵害其自由或權利，提起國家賠償訴訟，應為該公務員所屬機關為被告，當事人始為適格，並不得對該有故意或過失之公務員提起國家賠償訴訟。如人民逕向該有故意或過失之公務員提起國家賠償訴訟，依國家賠償法12條準用前揭民事訴訟法第249條第2項規定，逕以判決駁回之。二、經查，原告主張其因遭臺南市永康區公所清潔隊員吳瑞欽駕駛垃圾車撞傷，依國家賠償法第2條第2項規定，提起本件國家賠償訴訟，應以該公務員「所屬機關」即臺南市政府為賠償義務機關，原告併列吳瑞欽為被告，於法顯然不合，依前揭規定及說明，本件原告對於被告吳瑞欽請求國家賠償部分，在法律上顯無理由，應逕以判決駁回之。

### 臺灣新北地方法院114年度國字第20號民事判決

按國賠法第3條所定之國家賠償責任，係採無過失主義，即以該公共設施之設置或管理有欠缺，並因此欠缺致人民受有損害為其構成要件，非以管理或設置機關有過失為必要。所謂公共設施之設置有欠缺，係指公共設施建造之初，即存有瑕疵而言；

還願專用。嚴禁營利轉售



管理有欠缺，係指公共設施建造後未妥善保管，怠於修護致該物發生瑕疵而言（最高法院110年度台上字第2465號判決意旨參照）。2. 系爭道路存在系爭坑洞，欠缺使用上之安全性，核屬系爭道路存在之瑕疵。而觀諸現場照片（見本院卷第31、33、37頁），系爭坑洞之柏油路破損具有層次性且有龜裂裂痕，且該柏油路顏色並非新近鋪設，依經驗法則，柏油路面龜裂及層次性破損，應係長時間產生，應非短時間突然生成，從而堪認此瑕疵係被告長時間怠於修護所致，已足認被告之管理有欠缺。原告不慎踩入系爭坑洞因而受有系爭傷害，致其身體受損害，是原告依國賠法第3條第1項規定，請求被告負賠償責任，於法即屬有據。

#### 臺灣高等法院113年度勞上字第23號民事判決

另案確定判決認定被上訴人駕駛系爭列車運送乘客，係履行上訴人對蘇威豪之旅客運送契約，屬私法關係，且係因被上訴人超速及關閉ATP系統導致發生系爭行車事故，被上訴人對蘇威豪應負過失侵權行為損害賠償責任，上訴人則依民法第188條第1項規定與被上訴人連帶負損害賠償責任，為被上訴人所不爭執，如前所述，可見被上訴人駕駛系爭列車執行職務，並非處於國家機關之地位，行使統治權作用之公法行為，核與被上訴人以公務員身分執行公法上之職務，致侵害他人權利之情形有別，被上訴人就系爭行車事故既應依民事法律關係賠償乘客蘇威豪，上訴人對被上訴人即得依民法第188條第3項規定，對於被上訴人有求償權，被上訴人要無得割裂適用法律，一方面認上訴人與被上訴人對蘇威豪應連帶負民法侵權行為損害賠償責任，一方面認上訴人應類推適用國賠法第2條第3項規定，對被上訴人有求償權。況上訴人另案係依民法第188條第1項規定負擔雇主連帶賠償責任，就僱用人對行為人求償同條第3項已有規範，依前揭說明並無類推適用之餘地，是被上訴人抗辯：伊係上訴人任用之公務員，類推適用國賠法第2條第3項規定，伊執行職務有故意或重大過失時，上訴人對伊始有求償權云云，要無可採。

#### 最高法院101年度台上字第728號民事判決

次按人民之財產權應予保障，憲法第十五條設有明文。國家機關依法行使公權力致人民之財產遭受損失，若逾其社會責任所應忍受之範圍，形成個人之特別犧牲者，

國家應予合理補償。主管機關對於既成道路或都市○○道路用地，在依法徵收或價購以前埋設地下設施物妨礙土地權利人對其權利之行使，致生損失，形成其個人特別之犧牲，自應享有受相當補償之權利（司法院大法官會議釋字四四〇號解釋）。又私有土地供公眾通行已歷數十年，已成道路，在公法上雖應認有公用地役關係存在，其所有權之行使應受限制。惟該土地既未經徵收，仍為私人保留，則土地所有權人仍保有其所有權能，對於無權占有其土地者，仍得行使民法第七百六十七條之物上請求權，請求無權占有者返還土地，僅在公法上其所有權之行使應受不得違反供公眾通行之目的及不許擅自圍堵已成之道路或變更作建築基地之限制而已。

## 🗣️ 立法者的 OS

### 國家賠償法2條

本條第二項係本憲法第二十四條國家賠償之旨，規定國家對公務員之違法行為負擔損害賠償之要件。即：(一)須係公務員於執行職務行使公權力之行為；公務員於辦理不屬於行使公權力之職務行為，係屬一般私權關係事件，不在本法賠償之列。(二)須係故意或過失之行為，凡因災禍等不可抗力所致之損害，衡諸一般立法例，由於所採體制不同，或定為免責事由，或定為非屬賠償之範圍，均不在國家賠償之列。而此類事件應屬社會救助之範圍。(三)須行為違法，至適法行為，縱有損失，亦不發生依本法請求賠償責任問題。(四)須侵害人民之自由或權利，此項自由及權利，係指法律所維護及保障的一切自由及權利而言。公務員在執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民之自由權利，此種行為可包括積極的作為與消極的不作為。而公務員消極的不作為，亦即怠於執行職務，有侵害人民的自由或權利時，為使將來適用不致發生解釋的問題而有所爭執，爰規定凡符合此情況者，亦可請求國家賠償。

### 國家賠償法3條

四、由國家設置或管理，直接供公共或公務目的使用之公共設施，其範圍包括自然公物，例如：開放之山域或水域等。然利用大自然山域、水域等從事野外活動，性質上即具有多樣及相當程度危險性，人民親近大自然，本應知悉從事該等活動之危險性，

還願專用。嚴禁營利轉售

還願專用。嚴禁營利轉售

且無法苛求全無風險、萬無一失。是以，就人民利用山域、水域等自行從事之危險活動，在國家賠償責任上應有不同之考量與限制。就山域、水域等自然公物，各主管機關之管理目的多係以維持原有生態、地形與地貌為管理原則，故無法全面性地設置安全輔助設施，亦不宜或難以人為創造或改正除去風險，此與一般人工設置之公共設施（例如：公園、道路、學校、建物等），係由國家等設計、施作或管理，以供人民為該特定目的使用者，性質上仍有差異。因此，對此二類公共設施之課責程度亦應有所不同。爰增訂第三項規定，就開放之山域、水域等自然公物（例如：國家公園、森林遊樂區、海岸、沙灘、野溪及天然湖泊等），業經管理機關、受委託管理之民間團體或個人為適當之警告或標示，而人民仍從事冒險或具危險性活動情事者，國家於此狀況下不負損害賠償責任。至於管理機關、受委託管理之民間團體或個人應以何種方式為警告或標示乙節，考量各開放之山域、水域等所在場域位置之天候、地理條件各有不同，人民可能從事之活動，亦有差異，故所為之警告或標示，並不以實體方式（例如：標示牌、遊園須知告示、門票、入園申請書、登山入口處等適當處所警告或標示）為限，宜進一步考量景觀維持、環境保護、警告或標示之有效性、後續警告或標示維護等因素，綜合決定採用一種或數種方式，或於管理機關之網站為警告或標示，亦無不可。

五、另關於第三項所定「從事冒險或具危險性活動」情形，鑑於人民進入之地區、場域，所從事之活動、時間、天候狀況、環境條件，個人從事活動所需具備之專業知識、基本體能、技術、攜帶之器材裝備等情事，皆有不同，因而其行為是否具冒險或危險性，宜就具體事實，依一般社會通念及生活經驗等綜合判斷之。

六、於開放之山域、水域等自然公物區域範圍內，亦有可能設置其他直接供公眾使用之人工設施，例如：人工棧道、階梯、護欄、吊橋、觀景台、涼亭、遊客中心、停車場等，惟因該等設施坐落於開放之山域、水域內，使用該設施之風險未必皆能由管理機關等予以完全掌握控制，是以，如經管理機關等已就使用該人工設施為適當之警告或標示，而人民仍從事冒險或具危險性活動所致生之損害，不能完全歸責於國家，爰增訂第四項，於此情況下，得減輕或免除國家應負之損害賠償責任。

七、又第三項及第四項規定不負或減免損害賠償責任規定，其適用範圍僅限於開放之山域、水域等自然公物，及該等自然公物內之人工設施。至於非屬上開範疇之公共設施，仍應依具體個案事實，適用第一項、第二項規定，認定國家是否符合損害賠償要件；至請求權人如有與有過失之情形，則依第五條適用民法第217條規定辦理。

八、於第二項情形國家將公共設施委託民間團體或個人管理時，因受託之民間團體或個人管理欠缺致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家仍應負損害賠償責任，惟因損害之發生，乃直接肇因於民間團體或個人之管理欠缺所致，倘因國家賠償之後，民間團體或個人即可免責，亦非事理之平。是以，賠償義務機關於對人民為賠償後，自應依法向應負責任之民間團體或個人求償。又第四項之情形，人民於開放之山域、水域等自然公物內之設施從事冒險或具危險性活動發生意外，致生國家賠償，具體個案事實倘賠償義務機關不能免責，且有其他應負責任之人時，賠償義務機關於對人民為賠償之後，亦應依法行使求償權，爰將原第二項移列至第五項，並酌作文字修正。

## Q34 | 行政處分補票的「時間終點線」：未記明理

### 由之補正時限限制與程序正當性

行政機關對甲作成行政處分，但處分書中未記明理由，如無依法得不記明理由之情事，關於行政機關之補正，下列敘述何者錯誤？

(A) 甲無向原處分機關請求補正之權利，僅得提起行政爭訟請求撤銷原處分

(B) 僅有原處分機關可以補正處分理由，其上級機關不得為之

(C) 只要在行政訴訟事實審言詞辯論終結前補正處分理由，均屬適法

(D) 補正理由雖不足以支持原處分之合法性，亦不影響補正之效力

### Legal Basis | 法條依據

✿ 行政程序法114條1項：「違反程序或方式規定之行政處分，除依第一百十一條規定而無效者外，因下列情形而補正：

一、須經申請始得作成之行政處分，當事人已於事後提出者。

二、必須記明之理由已於事後記明者。

三、應給予當事人陳述意見之機會已於事後給予者。

四、應參與行政處分作成之委員會已於事後作成決議者。

五、應參與行政處分作成之其他機關已於事後參與者。」

✿ 行政程序法114條2項：「前項第二款至第五款之補正行為，僅得於訴願程序終結前為之；得不經訴願程序者，僅得於向行政法院起訴前為之。」

### Analysis | 破題思路

(A)

法未賦予甲向原處分機關請求補正之權利，其應該請求撤銷該處分，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故A不選。

(B)

僅有原處分機關可以補正處分理由，其上級機關不得為之，蓋若許上級機關得為之，將生處分責任歸屬不清之問題，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故B不選。

(C)

102年度訴更一字第24號判決，被告遲至訴願程序終結後之訴訟程序中，方補具上述理由，自不生補正原處分理由欠缺之效力。

「只要在行政訴訟事實審言詞辯論終結前補正，均屬適法」為錯誤之敘述，而本題要選錯誤的，故選C。

(D)

最高行政法院113年度上字第28號判決，處分機關將理由補充予當事人知悉，當事人也依該等理由，有向原處分機關陳明其意見的機會，以資決定是否撤銷或變更原處分者，就可認原處分的程序瑕疵已依上開規定而補正。

雖不足以支持原處分之合法性，亦不影響補正之效力，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故D不選。

### 🏛️ Court View | 法院目前怎麼看？

#### 臺北高等行政法院102年度訴更一字第24號判決

被告雖於原告正隆及榮成公司提起行政訴訟後，補稱：原告正隆公司及榮成公司在二級紙板全國市場的市場占有率合計為38.29%，業已超過「可察覺性」理論市場占有率總和5%之門檻，具有足夠之集體市場力影響市場供需功能云云，然依行政程序法第114條第1項第2款及第2項規定：「（第1項）違反程序或方式規定之行政處分，除依第111條規定而無效者外，因下列情形而補正：…二、必須記明之理由已於事後

記明者。…（第2項）前項第2款至第5款之補正行為，僅得於訴願程序終結前為之；得不經訴願程序者，僅得於向行政法院起訴前為之。」可見未記明理由之行政處分，應於訴願程序終結前補正其理由，始屬合法，則被告遲至訴願程序終結後之訴訟程序中，方補具上述理由，自不生補正原處分理由欠缺之效力。

#### 最高行政法院113年度上字第28號判決

復按行政處分作成前，未依行政程序法規定給予當事人陳述意見的機會而有程序瑕疵，依行政程序法第114條第1項第3款、第2項前段規定，若在訴願程序終結前，已由原處分機關將理由補充予當事人知悉，當事人也依該等理由，有向原處分機關陳明其意見的機會，供原處分機關參酌而重新審查原處分合法、妥當性，以資決定是否撤銷或變更原處分者，就可認原處分的程序瑕疵已依上開規定而補正。本件臺中市政府於收受原處分之理由後，已於嗣後提起訴願在訴願書中，針對原處分之理由陳明其不服之法律上意見，由被上訴人收受後，於訴願程序中以訴願答辯書，提出回應之法律意見，作為被上訴人重新審查原處分合法妥當性後，仍不依上訴人請求處置的答辯說明（訴願卷），參照前開說明，原處分作成前縱有未予上訴人陳述意見機會之程序瑕疵，亦已於嗣後依行政程序法第114條第1項、第2項規定而為補正，並無因此程序瑕疵而致形式違法之問題。

## Q35 | 最高規格程序的「司法直通車」：聽證後行政處分免除訴願之正當程序功能

依行政程序法規定，有關聽證之敘述，下列何者正確？

- (A)非經法規明文規定，行政機關不得舉行聽證
- (B)聽證，必要時得舉行預備聽證；但聽證終結後，行政機關不得再為聽證
- (C)聽證主持人，不論行政機關首長或其指定人員擔任，均應具備法制專長
- (D)不服依聽證作成之行政處分，其行政救濟程序，免除訴願及其先行程序

### Legal Basis | 法條依據

- ✦ 行政程序法107條：「行政機關遇有下列各款情形之一者，舉行聽證：  
一、法規明文規定應舉行聽證者。  
二、行政機關認為有舉行聽證之必要者。」
- ✦ 行政程序法58條1項：「行政機關為使聽證順利進行，認為必要時，得於聽證期日前，舉行預備聽證。」
- ✦ 行政程序法66條：「聽證終結後，決定作成前，行政機關認為必要時，得再為聽證。」
- ✦ 行政程序法57條：「聽證，由行政機關首長或其指定人員為主持人，必要時得由律師、相關專業人員或其他熟諳法令之人員在場協助之。」
- ✦ 行政程序法109條：「不服依前條作成之行政處分者，其行政救濟程序，免除訴願及其先行程序。」

## Analysis | 破題思路

(A)

行政程序法107條，行政機關舉行聽證以「法規明文」或「行政機關認為有舉行之必要」，故「非經法規明文規定，行政機關不得舉行聽證」為錯誤之敘述。

(B)

行政程序法58條1項，必要時，得於聽證期日前，舉行預備聽證，而66條聽證終結後必要時，得再為聽證，故「聽證終結後，行政機關不得再為聽證」為錯誤之敘述。

(C)

行政程序法57條，必要時得由律師或其他熟諳法令之人員在場協助，故「均應具備法制專長」為錯誤之敘述。

(D)

行政程序法109條，不服依聽證作成之行政處分，免除訴願及其先行政程序，為正確之敘述。

## 💡 立法者的 OS

### 行政程序法107條

聽證源於訴訟程序，後來亦適用於行政程序，於行政決定作成前，給予當事人就重要事實表示意見之機會，藉以避免行政機關之恣意專斷，保障當事人之權益。但若規定任何行政處分作成前均應舉行聽證，恐對人力、財力造成不必要之浪費，而影響行政效率，爰明定行政機關遇有本條各款情形之一者，始舉行聽證。